석사학위논문

취업규칙 불이익변경법리에 관한 연구

A Study on the Disadvantageous Change for the Rules of Employment

제 출 자 : 전 상 록

지도교수 : 하 갑 래

2017

노동법학과

노동법전공

단국대학교 행정법무대학원

취업규칙 불이익변경법리에 관한 연구

A Study on the Disadvantageous Change for the Rules of Employment

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2017년 5월

단국대학교 행정법무대학원
노동법학과
노동법전공

전 상 록

전상록의 석사학위 논문을
으로 판정함

심 사 일 : 2017. 5. 27.

심사위원장 양만식 인

심 사 위 원 최미나 인

심 사 위 원 하갑래 인

단국대학교 행정법무대학원

(국문초록)

취업규칙 불이익변경법리에 관한 연구

단국대학교 행정법무대학원 노동법학과
노동법전공
전 상 록
지도교수 : 하 갑 래

사용자는 취업규칙을 불이익하게 변경하기 위해서는 과반수노조, 과반수노조가 없는 경우 근로자과반수의 동의를 얻어야 한다. 「근로기준법」이 취업규칙 불이익변경의 요건을 규정한 취지는 단체협약이나 근로계약과 달리 사용자에 의해 일방적 또는 편무적으로 결정되는 한계를 보완하여, 근로자를 보호하려는데 있다.

취업규칙은 노동조합이 조직되지 않은 사업장에서 근로관계를 규율하는 집단적 규범으로 작용한다. 근로조건은 노사대등결정원칙에 따라 정해진다. 취업규칙은 사업장에서 법규범으로 인정되는 상태에서 사용자가 일방적으로 정하는 편무성을 가지고 있으므로 근로자보호를 위하여 근로자가 참여할 수 있는 제도적인 장치가 필수적으로 요청된다.

과반수노조 또는 근로자과반수의 동의라는 요건은 사용자로 하여금 근로조건을 경영환경의 변화나 노동시장의 유연화에 따라 대응하기 어렵게 만든다. 이러한 이유로 법원은 사회통념상 합리성이라는 기준을 적용하여 불이익변경인지를 판단해 왔다. 나아가서 법원은 사회통념상 합리성이 있으면 과반수노조 또는 근로자과반수의 동의를 받지 않아도 취업규칙의 효력이 인정된다는 법리를 형성하게 되었다.

다시 말해서 「근로기준법」은 취업규칙을 불이익하게 변경함에 있어 과반수노조 또는 근로자과반수의 동의라는 엄격한 절차를 명시적으로 요구하

고 있으나, 유연성을 확보하는 차원에서 동의규정을 배제하기 위한 방안으로 사회통념상 합리성법리를 인정하고 있다.

취업규칙 불이익변경은 입법적 흠결과 현실적 요청으로 해석론에 의존하고 있다. 그러나 해석론에 지나치게 의존하는 것은 취업규칙의 규범성을 약화시켜 궁극적으로 근로조건의 저하를 초래할 수 있다. 따라서 「근로기준법」이 현실과 괴리를 보이고 있는 점, 변경된 취업규칙의 효력에 대해 해석론에 의지하는 것은 바람직하지 않다는 점 등을 감안할 때 법원 판례의 내용을 입법의 영역으로 흡수하는 방안을 다음과 같이 제시하고자 한다.

첫째, 취업규칙을 변경함에 있어 불이익 변경여부와 동의여부를 중층적으로 판단하는 구조를 단순화하여, 취업규칙을 작성하고자 할 때는 근로자집단의 의견을 청취하게 하고, 변경하고자 할 때는 근로자집단의 동의를 받도록 하는 이론적인 구조로 제도가 재설계 되어야 한다.

둘째, 사회통념상 합리성은「근로기준법」의 동의 규정을 제외하는 효과를 가지므로 엄격한 요건을 전제로 하여 예외적으로 적용되어야 한다.

셋째, 취업규칙의 불이익변경에 관해 사회통념상 합리성법리가 예외적으로 적용되어야 한다는 점을 감안 할 때 동의의 효력에 대해서도 명시적으로 규정되어야 한다.

주제어: 취업규칙, 취업규칙 불이익변경, 근로자참여제도, 사회통념상 합리성, 동의주체와 방식, 동의효력

목 차

제1장 서 론 ····· 1
제1절 연구의 목적 ····· 1
제2절 연구의 범위와 방법 ····· 2

제2장 취업규칙 불이익변경법리의 이론적 배경 ····· 4
제1절 취업규칙제도의 의의 ····· 4
1. 개념 ····· 4
2. 기능 ····· 8
3. 법적성격 ····· 9
제2절 취업규칙 불이익변경법리의 근거 ····· 12
1. 취업규칙 불이익변경의 법적근거 ····· 12
2. 취업규칙 불이익변경법리와 근로자참여제도 ····· 15

제3장 취업규칙 불이익변경의 판단 ····· 23
제1절 불이익변경의 판단기초 ····· 23
1. 불이익변경의 개념 ····· 23
2. 취업규칙의 작성과 비교 ····· 23
3. 판단시점과 입증책임 ····· 25
제2절 불이익변경의 판단기준 ····· 26
1. 주관적기준과 객관적기준 ····· 26
2. 개별적판단과 종합적판단 ····· 27

제4장 불이익변경에 있어 근로자집단 동의의 한계 ····· 30
제1절 사회통념상 합리성법리와 동의불필요 ····· 30
1. 사회통념상 합리성법리 형성 ····· 30
2. 합리성과 불이익변경 ····· 30
3. 합리성과 동의불필요 ····· 35
제2절 동의의 효력 ····· 38
1. 효력의 일반원칙 ····· 38
2. 불이익변경과 사정변경 ····· 39
3. 신규입사자 ····· 39
4. 이의제기시효 ····· 40
5. 소급추인 ····· 41
6. 신고 및 주지의 효력관계 ····· 42

제5장 불이익변경법리의 문제점과 개선방안 ····· 45
제1절 불이익 판단구조 단순화 ····· 45
1. 불이익판단구조의 문제점 ····· 45
2. 기존 논의의 내용과 한계 ····· 46
3. 불이익 판단구조 개선방안 ····· 46
제2절 사회통념상 합리성법리의 법제도화 ····· 47
1. 사회통념상 합리성법리 적용형식의 문제점 ····· 47
2. 기존 논의의 내용과 한계 ····· 48
3. 사회통념상 합리성법리의 개선방안 ····· 50
제3절 동의의 효력에 대한 법제도화 ····· 51
1. 동의의 효력 적용형식의 문제점 ····· 51

2. 기존 논의의 문제점과 한계 ····· 52
3. 동의의 효력에 대한 개선방안 ····· 52

제6장 결 론 ····· 53

참고문헌 ····· 55

Abstract ····· 57

제1장 서 론

제1절 연구의 목적

취업규칙은 근로기준법(이하 “근기법”이라 한다) 제정 이후 사업장규범으로서 큰 역할을 해 오고 있다. 근기법은 사용자에게 취업규칙의 작성 또는 변경 권한을 부여하면서, 이를 통제하기 위한 방법으로 근로자에게 불리하게 변경되는 경우에는 근로자집단의 동의를 얻도록 하고 있다. 아울러 근기법은 취업규칙을 사용자가 일방적으로 작성하거나 변경할 수 있다는 점을 보안하기 위해 법령이나 단체협약에 위배할 수 없도록 하고, 국가감독을 위해 취업규칙의 작성·신고·게시 및 비치의 의무를 두고 있다.

취업규칙은 사용자와 근로자의 근로관계에 관해 기본적인 권리·의무와 근로조건을 포괄적으로 규정함으로써 노사 간의 불필요한 분쟁을 방지하고 근로자 보호에 기여해 온 것도 사실이다. 한국은 유럽과 달리, 근로자의 경영참가가 제한적이고 산별노동조합 중심의 집단적 근로조건결정시스템이 미약하므로 근로조건의 결정 및 근로자보호가 상대적으로 약할 수 있다. 비록 취업규칙의 법적 성질을 둘러싸고 이견은 있지만, 근로조건을 획일적 또는 통일적으로 설정하고 법령 및 단체협약, 근로계약과의 법적 관계 설정을 통해 근로자의 권익보호에 기여해 온 것은 높은 업적이라고 생각한다.

21세기에 접어들면서 산업화, 정보화 및 세계화 등이 진행되고 있다. 아울러 기업을 둘러싼 고용형태가 급격하게 변화하고 있고, 근로자들의 근로조건이 개별화되면서 노동조합 조직률이 하락하고 있으며, 집단적 근로조건 결정시스템이 약화됨에 따라 개별적근로관계가 더욱 중요해지고 있다. 특히, 한국의 노동시장은 IMF경제위기와 최근의 경제적 불황 등을 겪으면서 기존의 노동관계법만으로는 적절하게 대응하기는 한계가 있다. 또한, 집단적 근로조건결정시스템에 대한 기존의 패러다임에 대한 수정을 요구해야 한다는 문제의식 아래에서, 본 연구는 다음과 같은 연구목적을 둔다.

첫째, 취업규칙은‘사용자측의 편무성’을 보완하기 위해 근로자집단의 참여제도가 도입되었다. 그러나 대법원은 이 제도가 ‘근로자측의 일방성’으로 작용할 수 있는 여지가 있기 때문에 불이익변경 여부를 근로자에 맡기지 않는 입장을 보여주고 있다. 또한 인사관리에 관한 부분이나 근로조건의 변경에 대해 사회통념상 합리성이라는 판단기준 아래 불이익변경인지를 판단하는 일관성 있는 기준을 정립해 오고 있다. 그리고 동의를 받지 않는 취업규칙 변경에 대해 사회통념상 합리성을 이유로 신규입사자에게는 효력이 있다거나, 불이익변경된 취업규칙이 사정변경으로 인해 유리하게 적용된다면 효력이 있다는 법리를 형성하고 있다. 그러나 최근에 판례는 사회통념상 합리성을 근로자집단의 동의여부를 판단하는 기준으로 활용

하는 변화를 보여주었다. 이러한 변화는 변경된 취업규칙의 효력을 판단함에 있어 바뀌고 있음을 의미하므로, 본 논문에서는 판례법리의 구조가 어떻게 변하고 있는지를 검토 하고 한계를 분석해서 대안을 제시 하고자 한다.

둘째, 근기법은 취업규칙의 불이익변경에 있어 근로자집단의 동의를 받도록 규정하고 있지만, 어떤 형식과 방법을 통해 받아야 하는지를 구체적으로 명시하지 않고 있다. 취업규칙이 안고 있는 이러한 한계 때문에 판례를 중심으로 취업규칙의 규범성을 제한하려는 시도가 발견된다. 그 결과 해석론적으로나 입법론적으로도 취업규칙의 범규범성에 유연성을 부여하려는 시도들이 눈에 띈다. 또한 노동조합의 조직률도 떨어지면서 집단적 근로조건결정시스템제도가 약화되는 가운데 취업규칙제도의 지위도 흔들리고 있기 때문이다. 이러한 이유에서 근로자집단의 참여방법과 효력을 재조명하는 대안이 요구된다.

셋째, 근기법은 1953년에 제정과 1989년에 개정을 통해 취업규칙을 규정하고 정비해 왔다. 그 후 근기법은 취업규칙의 기재사항만 일부 추가되었을 뿐 현재까지 1989년 개정의 기본내용을 유지하고 있어 현실과의 상당한 괴리를 보여주는 부분도 있다. 따라서 본 연구는 이러한 관련 규정의 정비작업에 방향성을 제시함과 동시에, 새로운 고용환경에 맞도록 현대화하고 노동법제 간의 정합성을 추구하도록 재구성을 시도하는 것을 목적으로 한다.

제2절 연구의 범위와 방법

취업규칙의 불이익변경법리와 관련해서 선행 연구는 법리적인 분석보다 대법원 판례나 행정해석을 소개하는데 초점을 맞추고 있다. 선행연구의 이러한 업적은 취업규칙의 불이익변경법리를 전반적으로 분석하는데 있어, 필수적으로 요청되는 과정이다. 따라서 이 논문은 선행연구의 업적을 기초로 취업규칙의 불이익변경법리의 체계적인 분석을 통해 문제점과 개선방안을 다룬다. 이를 위해 이 논문이 활용한 연구방법은 첫째, 국내의 단행본, 논문 및 정부보고서 등을 분석하는 문헌연구를 기본으로 삼는다. 둘째, 판례와 학설을 분석하는 법해석론적 방법을 활용한다. 셋째, 일본의 「노동기준법」이나 「노동계약법」의 입법방향과 내용을 한국 실정에 적용시킬 수 있는 지를 검토하고 판단하는 비교법적 방법을 부분적으로 병행한다, 넷째, 구체적인 법안의 마련을 염두에 두고 조문으로 연결될 수 있도록 구체적인 방안을 제시하는 입법론적 방법을 활용한다. 따라서 본 논문은 이러한 연구방법 아래에서 총 6장으로 구성한다.

제2장은 취업규칙 불이익변경법리의 일반론을 고찰한다. 제1절에서는 취업규칙제도의 개념, 기능 및 법적 성격에 관해 검토한다. 제2절에서는 취업규칙 불이익변경에 관해 법적근거를 살펴본 후, 불이익변경의 일방성과 편무성을 보완하기 위해 마련된 근로자참여제도에 관해 검토한다.

제3장은 취업규칙 불이익변경에 관한 판단 기초와 기준을 다룬다. 제1절에서는 불이익의 개념, 변경과 작성의 비교, 판단시점과 입증책임을 검토한다. 제2절에서는 불이익변경의 판단 기준을 누가 판단하는 지에 따라 주관적 기준과 객관적 기준의 견해의 대립을 정리한 후, 근로조건과 적용대상 근로자 기준별로 개별적 판단과 종합적 판단으로 나누어 각각 분석한다.

제4장은 불이익변경에 있어 근로자집단 동의의 한계를 규명한다. 제1절에서는 사회통념상 합리성법리와 함께 동의의 필요여부를 다룬다. 이때 일반적인 합리성법리를 다룸에 있어 원칙적 판단기준과 부가적 판단기준까지 검토한다. 제2절에서는 동의의 효력을 다루면서 효력의 일반원칙을 시작으로 신고 및 주지 의무와의 관계까지 다룬다.

제5장은 불이익변경법리에 문제점을 지적하고 개선방안을 제시한다. 제1절은 불이익 판단 구조에 대해, 제2절은 사회통념상 합리성법리에 대해, 제3절은 동의의 효력에 관해 각각의 문제점과 한계를 검토한다. 아울러 각 장의 검토를 토대로 하여 입법론적 개선방안을 제시하면서, 결론으로 마무리 하고자 한다.

제2장 취업규칙 불이익변경법리의 이론적 배경

제1절 취업규칙제도의 의의

1. 개념

(1) 법적근거

「근로기준법」(이하 “근기법”이라 한다)은 취업규칙에 관해서 제9장에서 5개 조문을 두고 있다(제93조 - 제97조). 그럼에도 불구하고 근기법은 취업규칙의 개념을 정의하는 규정은 두고 있지 않다. 취업규칙은 일반적으로 사업장에서 근로자가 지켜야 할 근로조건 또는 복무규율에 관해 구체적인 내용을 정한 규칙 모두를 일컫는다.[1] 상시 10명 이상 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장은 취업규칙을 고용노동부에 신고해야 되는데(근기법 제93조), 취업규칙에 해당 하려면 실체적인 요건뿐만 아니라 절차적인 요건이 요구된다.

(2) 실체적 요건

1) 근로조건과 복무규율에 관한 기준

근로조건은 사용자와 근로자가 개별적으로 정하는 것이 원칙이다. 그러나 사용자가 현실적으로 다수의 근로자와 매번 근로조건 등을 정하는 것은 번거로운 일이다.[2] 또한, 기업을 존립시키고 사업 또는 사업장에서는 이를 원활하게 운영하기 위해서 기업질서를 유지·확립하는 것 또한 필요하다.

근로조건은 사용자와 근로자 사이의 근로관계에서 임금·근로시간·후생·해고, 그 밖에 근로자의 대우에 관하여 정한 조건을 말한다.[3] 복무규율은 근로자가 근로를 제공하는 과정에서 지켜야 할 작업질서에 관한 규칙과 이를 위반하였을 경우 가해지는 제재를 포함하는 개념이다.[4] 따라서 근로조건이나 복무규율 등 근로관계를 직접 규율하는 내용을 담고 있지 않은 부분은 취업규칙의 성격을 갖지 않는다는 견해가 있다.[5] 취업규칙의 본질을 생각할 때

---

1) 하갑래, 『근로기준법』 제29판, (주) 중앙경제, 2017, 142쪽.
2) 김형배, 『노동법』 제24판, 박영사, 2015, 294쪽.
3) 대법원 1992.6.23. 선고 91다19210 판결.
4) 대법원 1994.6.14. 선고 93다62126 판결; 대법원 1993.3.26. 선고 98두4672 판결.
5) 노동법실무연구회, 『근로기준법 주해 Ⅲ』, 박영사, 2010, 445쪽.

이러한 견해는 타당하다고 생각한다.

2) 집단적·통일적 규율

근기법은 취업규칙에 기재할 내용에 관해 12개 사항을 열거하고 있다. 동법 제93조 제12호는 "해당 사업 또는 사업장의 근로자 전체에 적용될 사항"이라고 명시함으로써 취업규칙이 근로자집단에 적용될 근로조건과 복무규율을 규정하는 수단임을 명확히 하고 있다.[6] 또한, 취업규칙은 노사간의 집단적인 법률관계를 규정하는 법규범의 성격을 갖는 것이므로 명확한 증거가 없는 한 그 문언의 객관적 의미를 무시하는 해석이나 사실인정은 신중하고 엄격하여야 할 것으로 생각된다.

취업규칙은 집단적으로 근로조건을 설정하는 수단이라는 점에서 개별적으로 근로조건을 설정하는 수단인 근로계약과 구별되는 반면, 단체협약과 유사한 면이 있다. 단체협약도 근로조건을 집단적으로 규율하는 특성을 가지고 있지만, 이는 노동조합의 조직을 전제로 하기 때문에 노동조합이 조직되지 않는 사업장에서는 취업규칙이 유일한 집단적 자치규범이 된다.[7]

따라서 취업규칙은 근로조건의 기준을 정형화한 일종의 경영규범이므로 하나의 사업 또는 사업장에 하나의 취업규칙이 존재하는 것이 바람직하다. 그러나 사업장 내의 근로자가 그 근무형태 또는 대우 등을 달리하는 여러 집단으로 나뉘는 경우에는 각 집단의 근로자들을 적용 대상으로 하는 취업규칙을 별개로 작성할 수 있다. 근기법과 「근로기준법 시행령」(이하 "근기령"이라 한다)은 단시간 근로자에 대해 적용되는 취업규칙을 통상근로자에게 적용되는 취업규칙과 별도로 작성할 수 있다고 함으로써, 일부 근로자 집단에게 적용되는 취업규칙을 작성할 수 있음을 입법적으로 인정하고 있다(근기법 제18조, 근기령 제9조 별표2).[8] 이에 관해 대법원은 같은 사업장에 소속된 모든 근로자에 대하여 일률적으로 적용되는 하나의 취업규칙만을 작성하는 것은 아니고, 근로자의 근로조건, 근로형태, 직종 등의 특수성에 따라 근로자 일부에 적용되는 별도의 취업규칙을 작성할 수 있으며, 이 경우 여러 개의 취업규칙을 합한 것이 법 소정의 1개의 취업규칙으로 된다고 판시하고 있다.[9] 그러나 이원화된 취업규칙이라 하더라도 법령이 정한 차별금지규정(근기법 제6조)과 퇴직금차등금지규정(근퇴법 제4조 제2항)을 위반할 수 없다.

---

6) 대법원 2003.3.14. 선고 2002다69631 판결.

7) 하갑래, 앞의 책, 143쪽.

8) 임종률 외 7인, 「근로기준법제의 중장기적 개선 방안 연구」, 노동부 2007, 163쪽. 단시간근로에 대한 규정이 근기법과 기단법으로 이원화되어 있는 것은 입법적불비로 보여 지기 때문에 기단법으로 통일하자는 견해가 제시된다.

9) 대법원 1992.2.28. 선고 91다30828 판결; 대법원 1996.2.27. 선고 95누15698 판결; 대법원 1998.3.24. 선고 96다24699 판결; 대법원 2000.2.25. 선고 98다11628 판결; 대법원 2007.9.6. 선고 2006다83246 판결.

3) 사용자가 일방적으로 결정하는 편무성

취업규칙은 사용자가 일방적으로 작성하는 준칙이다.[10] 취업규칙이 근로관계 규율에서 근로계약이나 단체협약보다 중요한 역할을 담당하고 있는 현실에서 사용자에 의하여 일방적으로 작성되는 것을 허용하는 것은 근로조건 등을 사용자가 단독으로 결정하고 이를 좌우할 위험성을 내포하고 있다.[11] 근기법은 비록 사용자가 일방적으로 작성하는 취업규칙을 승인하여 법적 제도로 편입하는 한편, 사용자의 일방적인 취업규칙 작성·변경에 대하여 다양한 법적 규제를 가함으로써 근로자를 보호하고 근로조건대등결정의 원칙을 구현하고자 한다.

4) 명칭을 불문하는 실체성

취업규칙은 근로자 집단에게 집단적·통일적으로 적용될 복무규율과 근로조건에 관한 준칙의 내용을 담고 있고, 이를 취업규칙이라는 명칭으로 되어 있는 경우가 일반적이다. 그렇지만 취업규칙이라는 명칭 이외에도 사규, 내규, 규정 등으로 존재하며 근로자집단에게 통일적으로 적용될 근로조건에 관한 준칙을 정한 것이라면 그 명칭을 상관하지 않는다.[12]

대법원은 집단적으로 작성해서 근로자에게 일률적으로 적용시키는 근로계약서도 취업규칙으로 본다.[13] 구체적으로 취업규칙이 복무규율과 임금 등 근로조건에 관한 준칙의 내용을 담고 있으면 그 명칭을 불문하는 한편, 복무규율과 임금 등에 관한 내용을 담고 있는 근로계약서를 별도로 작성하여 50여 명에 이르는 일용직 근로자들에게 일률적으로 적용하고 있는 근로계약서도 일용직 근로자들을 대상으로 작성 한 임금 등 근로조건에 대한 준칙의 내용을 담고 있다면 이를 취업규칙으로 인정한다는 것이다. 나아가서 종업원의 근로조건 변경을 목적으로 한 자구계획서, 학교법인의 정관, 제분 회사 공장의 상하차 반원들과 사이에 체결된 노역계획서, 이사회 결의, 지역의료보험조합 운영규정, 유휴인력활용지침, 신원보증규정도 그 명칭에 관계없이 취업규칙으로 보는 견해도 있다.[14] 이러한 견해가 받아들여지려면 그 내용이 단순한 결의에 그쳐서는 안 되며, 내용을 명시하여 근로자 집단의 의견을 묻고, 법률효과를 발생코자 하는 의사표시로 인정되어야 한다.[15] 비록, 형식상의 명칭을 사용하지 않더라도 근로조건과 복무규율이라고 하는 내용을 명시하고 변경되는 부분이 있을 경우 실질적인 판단을 통해 취업규칙임이 판단되어야 할 것이다.

---

10) 임종률, 『노동법』 제14판, 박영사, 2016, 353쪽; 김형배, 앞의 책, 294쪽; 하갑래, 앞의 책, 143쪽.
11) 노동법실무연구회, 앞의 책, 447쪽.
12) 대법원 1994.5.10. 선고 93다30181 판결; 대법원 2004.2.12. 선고 2001다63599 판결 등.
13) 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결.
14) 노동법실무연구회, 앞의 책, 448-449쪽.
15) 하갑래, 앞의 책, 146쪽.

(3) 절차적 요건

근기법 제93조는 취업규칙을 작성하여 고용노동부장관에게 신고하도록 규정하고 있고, 동법 제116조는 이를 위반하면 500만원 이하의 과태료를 부과한다고 규정하고 있다. 취업규칙을 작성해서 신고해야 하는 의무자는 상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자이다. 행정해석에 따르면 취업규칙을 신고할 때는 작성된 취업규칙 전체, 변경된 취업규칙 전체, 근로자의 의견서 및 단체협약이 있는 경우에 단체협약을 제출하도록 요구하고 있다.[16]

작성·신고 의무가 없는 10명 미만의 근로자를 사용하는 사용자가 취업규칙을 작성 했다면 이를 취업규칙으로 보는지 문제가 발생한다. 우선, 5명이상 10명 미만 근로자를 사용하는 사용자는 근기법 적용 대상이므로 취업규칙의 규범적인 효력이 인정 될 수 있으나 근기법 제93조가 신고의무자를 10명 이상 사용자로 규정하고 있기 때문에 신고의무는 없는 것으로 해석된다. 다음으로, 상시 근로자가 4명 이하인 사용자에게는 취업규칙 규정이 적용되지 않으므로 임의로 취업규칙을 작성하여 운영하더라도 법규범적효력을 인정하기 어렵다.[17]

(4) 검토 및 사견

취업규칙은 실체적인 요건에 대해 이견이 없다. 다만, 절차적인 요건에서 우선, 작성의무자인 10명 이상 근로자를 사용하는 사용자인 경우 근기법의 적용범위를 규정하고 있는 제11조와 비교 해볼 때 형평성에 어긋난다. 5명 이상 10명 미만 사업 또는 사업장의 경우 근기법 제9장의 취업규칙 관련 조문이 적용되어 규범적 효력을 인정하는 점을 볼 때 근기법 적용인 제11조와 범위를 일치 시켜 5명 이상으로 적용하는 것이 타당하다고 본다. 다음으로, 신고의무위반에 관해서 근기법은 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있는데, 과태료 적용은 별론으로 하고 취업규칙의 효력을 인정하는 견해가 다수이다.[18] 근기법이 신고의무를 부여 하는 것은 취업규칙의 실효성을 높이기 위함인데 이를 효력 요건으로 보지 않는다는 것은 신고의무를 부여한 취지에 반감이 된다. 그렇다고 해서 실효성을 높이기 위해 과태료를 높이는 등의 방법보다는 신고의무 규정을 삭제하고 실효성을 제고하는 방안이 검토되어야 할 것이다. 이와 관련해서 주지의무 부분에서 다시 다룬다.

---

16) 근기-1118, 9.4.24.
17) 근기-2046, 2005.12.28.
18) 임종률, 앞의 책, 364-365쪽; 김형배, 앞의 책, 301쪽; 하갑래, 앞의 책, 150쪽; 노동법실무연구회, 앞의 책, 459쪽 등.

2. 기능

(1) 근로조건의 결정기능

근로자가 동일 장소에서 집단적으로 노동력을 제공하는 경우 근로자들끼리 상호 협력 하에 이루어져야 하므로, 협력적·집단적 노동력이 제공되는 사업장에서는 획일적·통일적인 근로조건의 규율을 담은 집단적 규범이 필요하다.

따라서 취업규칙의 중요한 기능은 근로자의 근로조건을 결정하는 기능임과 동시에 제반 근로조건에서 발생하는 분쟁을 취업규칙의 규정에 의거해서 해결을 하고자 하는데 그 목적이 있다.[19]

취업규칙의 이러한 목적은 근로조건이 개개의 근로자에 응하게 되는 경향 다시 말해, 근로조건의 개별화경향이라고 하는 것이 서서히 약하게 될 때라는 견해가 있다.[20] 이 견해에 따르면 취업규칙은 근로조건의 획일적이고 통일적인 결정을 수행하기 때문에 개별적이고 구체적인 근로조건을 결정하는 데에는 부합하지 않다는 것이 그 논리적 근거이다. 그러나 다수의 근로자가 협력적으로 일하는 형태가 변경되지 않는 이상 근로조건이 집단적으로 결정되어진다는 점에서는 특별한 변화가 없을 것이라고 생각한다.

(2) 인사관리지침으로서의 기능

취업규칙의 기능은 근로조건 결정기능에 한정되지 않는다. 취업규칙은 회사에 있어서 인사관리의 실무를 담당하는 자에게 인사관리지침으로서의 기능도 있다.[21] 즉, 인사관리 담당자는 취업규칙의 규정을 무시하고 독자적으로 직무를 수행할 수는 없다. 취업규칙에서는 인사관리에 관한 모든 사항을 규정하지 않기 때문에 인사관리 담당자에게 어느 정도 재량권이 있는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 이것은 근로자의 근로조건과 관계가 있는 이상 사용자의 입장에서 인사관리를 담당하는 자에게 폭넓은 재량을 부여하는 것은 적절하지 않다.

취업규칙의 규정은 사용자측이 자의적으로 운용하지 않도록 구체적이고 명확해야 한다.[22] 왜냐하면 노사간의 권리와 의무를 명확히 하는 것이 분쟁을 방지하고 원만하고 원활한 직장의 의무를 수행할 수 있도록 하기 때문이다.

---

19) 김 철, “취업규칙제도에 관한 연구”, 경희대 박사논문, 2010.2, 19쪽.
20) 강희원・선미란, “취업규칙의 본질에 관한 일고찰”, 「외법논집」 제37권 제2호, 한국외국어대 법학연구소, 2013.5, 238쪽.
21) 조득주, “취업규칙제도에 관한 연구”, 고려대 박사논문, 2008.2, 17쪽.
22) 김 철(2010), 앞의 논문, 20쪽.

3. 법적성격

(1) 견해의 대립

근기법은 상시 10명 이상 근로자를 사용하는 사용자에게 작성의무를 부과하고(근기법 제93조), 취업규칙에서 정한 기준을 하회하는 근로계약의 부분은 무효이다(근기법 제97조). 또한 취업규칙은 법령이나 해당 사업 또는 사업장에 대하여 적용되는 단체협약과 어긋나서는 아니되며, 고용노동부장관은 법령이나 단체협약에 어긋나는 취업규칙의 변경을 명할 수 있다(근기법 제96조). 나아가 단체협약에서 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 취업규칙은 효력이 없으며, 이 때 무효로 된 부분에 대해서는 단체협약에 정한 기준에 의하도록 규정하고 있다(노조법 제33조).

근기법상 규정들은 제정부터 현재까지 수많은 개정을 거쳤음에도 불구하고 취업규칙의 법적성격은 현재까지도 논란이 되고 있다. 이에 관해 학계에 논의를 살펴보면 법규범설의 입장과 계약설의 입장으로 견해의 대립이 있다. 우선, 법규범의 입장은 취업규칙을 법규범으로 보고 구체적으로 기업소유권설, 사회자주법설, 수권설 등으로 나뉜다. 다음으로, 계약설의 입장은 취업규칙의 법적 성질을 계약으로 파악하데, 이 입장도 구체적으로 순수계약설, 사실인 규범설, 사실인 관습설 등이 있다. 이하에서는 각 학설에 관한 주장근거에 대해서 살펴보기로 한다.

(2) 법규범설

1) 기업소유권설

기업소유권설은 기업주와 근로자의 관계를 지배복종의 관계로 보고, 사용자는 당연히 그의 기업에 대한 소유권에서 취업규칙을 작성 할 수 있으며 지배복종의 관점에서 볼 때 권력관계의 지배자라고 한다.[23] 이 견해에 따르면 사용자의 행위는 당연히 근로자를 구속할 수 있다고 보고, 기업질서를 설정하여 근로자를 지배하기 때문에 사용자의 경영체 관리권능도 근로자 지배권능으로 되는 것으로 본다. 따라서 취업규칙은 사용자의 소유권에 근거하여 창설된 경영체의 질서이고 그러한 소유권을 국가가 법적으로 보장하기 때문에 법규범으로 된다고 하는 견해이다. 이런 점에서 기업소유권설은 기업주고유권설, 소유권설 또는 경영권설 등으로 불린다.[24]

---

23) 이 정(譯), 『日本勞動法』, 법문사, 2007, 114쪽.
24) 이 정 외 2인, 「취업규칙 분석 및 제도개선 방안 연구」, 노동부, 2009, 48쪽.

2) 사회자주권설

사회자주권설은 취업규칙이 사업장이라는 사회에 있어서 현실적으로 존재하고 관습적으로 인정되어 온 사회적 법규범이라고 보는 견해이다.[25] 이 견해는 법적 근거를 국가의 수권으로 보지 않고, 공공질서 또는 선량한 풍속에 위반하지 않는 관습을 법령에 의해 인정한 것 그리고 법령에 규정이 없는 사항에 관해 법률과 동일한 효력을 가지는 것으로 이해하고 있다.[26] 이런 의미에서 관습법설 이라고도 한다. 그러나 관습법이 성립하기 위해서는 관습이 존재하여야 하는 것은 당연한데, 취업규칙이 처음 만들어진 경우에도 이러한 관습이 존재하는지에 관해서는 설명하기 어렵다.

3) 수권설

수권설은 사회규범을 법규범시하는 근거는 그 사회규범을 지지하는 법적 확신에 있다는 명제하에서 취업규칙의 법적 성질을 규명하고자 한다. 이 설에 의하면 사용자가 일방적으로 제정하는 취업규칙은 단체협약과는 달리 법적 확신에 의해 지지되는 사회규범이 아니지만, 노동보호입법의 입법목적으로부터 그 자체가 법규범성을 갖지 않음에도 불구하고 법적 효력이 있는 것으로 보는 입장이다.[27] 이러한 입장은 취업규칙에 관한 노동법체계상의 지위에 조응하여 법규범성의 근거를 근로자보호라는 입법정책적 근거에 연결시켜 근로기준법의 규정이 취업규칙에 대하여 법규범을 창설적으로 부여하는 것으로 보는 것이다. 취업규칙의 법적 성질을 수권설의 입장에서 이해하는 견해는 근기법 제93조가 사용자에게 작성의무를 강제하고, 제96조에서 규범적 효력을 인정함으로써 법이 근로자보호를 위하여 법규범의 효력을 승인한데서 법규범성이 생긴다고 보고 있다. 대법원도"근기법이 종속노동관계의 현실에서 실질적으로 불평등한 근로자의 입장을 보호 강화하여 그들의 기본적 생활을 보호 향상시키는 목적의 일환으로 그 작성을 강제하고 이에 법규범성을 부여한 것"이라고 판시하고 있어,[28] 수권설의 입장을 취하는 것으로 생각된다.

(3) 계약설

1) 순수계약설

---

25) 김치선, 『노동법강의』 제2판, 박영사, 1988, 250쪽.
26) 이 정 외 2인, 앞의 보고서, 48-49쪽.
27) 임종률, 앞의 책, 355쪽; 하갑래, 앞의 책, 144-145쪽.
28) 대법원 1977.7.26. 선고 77다355판결.

순수계약설은 근로자에 있어서 취업규칙의 내용은 근로계약관계 상 중요한 요소를 이루며, 사용자가 일방적으로 정하는 취업규칙은 일반적 계약조건으로 당사자 합의를 통해서 비로소 계약의 내용이 된다는 것이다.[29] 이 견해에 따르면 근로자가 근로관계를 성립하기 이전의 취업규칙은 근로계약을 체결할 의사를 표시한 사용자의 일방적 청약에 불과하고, 근로자가 경영체에 편입됨으로써 취업규칙의 적용에 대해 동의를 표시하는 것으로 보는 입장이다.[30] 여기서 취업규칙은 일종의 부합계약의 유형으로 보는 것이며, 근로자는 취업규칙이 제정되었다는 것을 아는 자체로 족하다. 더 나아가 근로자가 구체적인 것을 알지 못하더라도 취업규칙에 의하여 구속되는 것이며,[31] 그 자체가 사실에 지나지 않아 당사자의 합의에 의하여 법적 의미를 취득하게 된다고 설명하고 있다.

2) 사실인 규범설

취업규칙은 사용자가 일방적으로 정한 근로조건에 대해 사실상 기준인 사실규범으로 보는 견해이다.[32] 이 입장에 따르면 사용자의 일방적 결정에 대해 법규범성을 인정하는 것은 계약개념에도 배치한다고 보며, 취업규칙을 사실상 규범에 불과한 것으로 본다.[33] 그러나 취업규칙에 의한 일방적인 근로조건의 결정은 계약원리와 배치되므로 그 자체로 어떠한 법적인 효력을 가질 수 없고, 당사자의 합의에서 그 근거를 찾아야 한다는 점에서는 순수계약설과 다른 차이를 발견하기 어렵다.

3) 사실인 관습설

사실인 관습설은 취업규칙이 근로계약에 대해 공통적인 내용으로 작용한다는 점에 대해 사실상 법규범과 같은 역할을 하지만,[34] 근로관계의 일방적인 당사자인 사용자에게 법규범을 설정할 근거는 없으므로 법규범이라 할 수 없다는 입장이다. 또한 취업규칙은 청약적 성질을 가지고 있기 때문에 근로계약의 내용으로 받아들이기 위해서는 어떠한 형태든 근로자의 동의를 전제로 해야 한다는 것이다.[35] 그러나 현실적으로 근로자들과 매번 구체적인 합의를 한다는 것은 어려운 일이다. 그러므로 근로자는 취업규칙 그 자체에 대하여 반대의 의사를

29) 이 정 외 2인, 앞의 보고서, 50쪽.
30) 김형배, 앞의 책, 297-299쪽.
31) 이 정 외 2인, 앞의 보고서, 51쪽.
32) 이상윤, 『노동법』 제14판, 법문사, 2015, 408쪽.
33) 이 정 외 2인, 앞의 보고서, 51쪽.
34) 김형배, 앞의 책, 298쪽.
35) 이 정 외 2인, 앞의 보고서, 51-52쪽.

표시하지 않는 이상, 취업규칙의 내용이 근로계약의 내용으로 되는 것을 승인한 것으로 볼 수 있다.[36]

따라서 취업규칙에 대한 반대의 의사를 표시하지 않는 한, 취업규칙에 의한다는 사실인 관습을 기초로 근로자의 동의라는 요소를 매개하여 그 전체가 근로계약의 내용으로 된다고 이해하고 있는 것으로 평가할 수 있다.

(4) 검토 및 사견

취업규칙에 어떠한 효력을 부여할 것인지는 입법정책적인 문제이다. 비록, 입법정책적인 문제라고 해도 계약설을 지지하는 견해가 근기법 규정과 배치되는 것은 아니다. 왜냐하면 입법정책적인 문제와 법적성격과는 별개의 문제이기 때문이다.

다만, 근기법은 사용자로 하여금 작성을 강제하고 있다는 점, 그렇게 작성된 취업규칙에 법적효력을 인정한다는 점, 불이익 변경에 대해서 집단적 동의를 받아야 하는 점을 볼 때 법규범설 중에 수권설이 타당하다고 생각한다.

제2절 취업규칙 불이익변경법리의 근거

1. 취업규칙 불이익변경의 법적근거

(1) 1953년 제정 근기법에서 취업규칙제도 마련

근기법은 1953년에 헌법에 의거하여 근로조건의 기준을 정함으로서 근로자의 기본적인 생활을 보장 향상시키며 균형 있는 국민경제의 발전을 기여하려는 목적으로 제정되었다. 제정 근기법은 제9장에서 취업규칙의 작성신고와 작성변경절차 등을 마련하고 있다.[37] 제정 근기법은 우선, 취업규칙의 작성신고와 관련해서 10명이상 근로자를 사용하는 사용자에게 작성의무를 부여하고 사회부에 신고하도록 규정을 두고 있다(제94조). 다음으로, 작성 변경 절차에 관해 당해 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자에 의견을 들어야 하도록 규정하고 있다(제95조).

제정 당시 상황과 관련하여 사회보건위원장의 법률안 외에 취업규칙부분에 관하여 단 하나의 수정안이 있었을 뿐이다. 이 과정에서 1953. 4. 7. 제15차 국회 제48차 회의 제2독회가

36) 이 정 외 2인, 앞의 보고서, 52쪽.
37) 노동부, 「근로기준법 연혁집」, 노동부, 2008, 3쪽.

때에, 송방용 의원이 “이 근기법안은 나온 지도 이미 오래되었고 또 노동운동하시는 분들이 여기에 관심을 가지고 이미 수정안도 낸 분도 있고 해서 수정안이 없는 부분에 있어서는 별로 논의할 것이 없을 줄로 압니다. 앞으로 우리가 심의할 안건도 많기 때문에 시간을 좀 절약하기 위해서 수정안 있는 조항만 심의하기로 하는 것이 좋다고 해서 의사진행으로서 여기에 와서 동의를 합니다.”고 하였고, 이의 없이 채택되었다. 따라서 제2독회의 축소심의는 수정안이 있는 쟁점을 중심으로 논의되었고, 별다른 수정안이 없었던 취업규칙은 원안대로 통과되어 법령이나 단체협약에 저촉되는 취업규칙의 “변경을 명 할 수 있다”로 제정되었다. 제정 당시 근기법의 이러한 체계는 입법을 마련할 당시에도 크게 문제가 되지 않았고 별다른 수정안이 없었을 뿐만 아니라 이의 없이 원안이 통과되었다.[38] 이는 정부수립 후에 혼란한 정국아래에서 외국 법제를 면밀히 조사해서 반영할 시간조차 없었기 때문에 급하게 마련한 입법이라고 생각한다.

(2) 1989년 개정 근기법에서 불이익변경에 대한 근로자집단의 동의제도 도입

제정 근기법에서 취업규칙의 이러한 규정은 1989년 3월 29일에 비로서 개정에 이르게 되는데(법률 제4099호), 1977년 대법원 판결이 결정적인 계기가 되었다. 제정 근기법은 취업규칙의 변경에 있어 유·불리를 논하지 않았다. 다만, 취업규칙 변경의 경우에는 유·불리와 무관하게 과반수 대표에 대한 의견청취만이 있었을 뿐이다. 그럼에도 불구하고 1977년 대법원 판결이 불리한 변경의 경우에는 근로자집단의‘동의’를 받아야 한다고 판시함에 따라[39] 개정 근기법이 이를 반영하였다.

1989년 3월 29일의 개정 근기법은 “불이익변경에 대한 근로자집단의 동의”를 마련하고 근로자과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우 근로자집단을 “근로자 과반수를 대표하는 자”에서 “근로자과반수”로 바뀌었다.

제13대 국회의 노동위원회에는 개정 논의 당시에 야3당이 각각 근기법 개정안을 제출 하였다. 신민주공화당은 “당해 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자의 동의를 얻어야 한다”는 내용을 담고 있었고, 통일민주당과 평화민주당은 “근로자 과반수동의”만을 내용으로 하고 있었다. 그 후 여야간에 별다른 이의없이 “근로자의 과반수를 대표하는 자”가 아닌 “근로자의 과반수 동의”를 규정하게 되었다.[40]

대법원은 취업규칙 작성·변경에 근로자의 집단적동의 규정이 없음에도 불구하고 이미 집

38) 강희원・선미란, 앞의 논문, 235-236쪽.
39) 신권철, “취업규칙을 넘어 - 판례 법리와 그 비판 -”, 「노동법연구」 제41호, 서울대 노동법연구회, 2016 하반기, 26쪽.
40) 강희원・선미란, 앞의 논문, 242-243쪽.

단성을 요구하지는 않더라도 불이익변경에는 근로자의 동의가 필요하다는 제한을 사용자에게 요구해 왔다. 구체적으로 "대법원 1977, 7, 26. 선고 77다355 판결"에서는 취업규칙을 불이익하게 변경할 때 근로자 과반수의 집단적 의사결정에 의한 동의를 요건으로 제시하였다. 이때 대법원은 과반수의 동의를 얻지 않은 취업규칙의 불이익변경은 무효로 보았으며, 1989년 3월 근기법 개정에서 현행 제94조 제1항 단서와 같은 불이익한 변경 시에는 동의를 얻어야 하는 것으로 변경되었다. 이는 민주화운동등의 영향으로 근로자의 권리의식을 높이려는 사법부의 입장이 입법부에게 까지 영향을 미친 것으로 보인다. 따라서 근로조건대등결정의 원칙을 구현하고 있다는 점에서 긍정적 평가를 받는다.[41]

(3) 2005년과 2008년 개정 근기법에서 취업규칙 기재사항 추가

2005년5월31일 법률 제7566호로 개정된 근기법은 산·전후휴가, 모성보호 그리고 육아휴직을 정비하였다. 그 핵심은 사용자가 임신 중인 여성뿐만 아니라 임신 중인 여성이 임신 16주 이후 유산 또는 사산한 경우로서 당해 근로자가 청구하는 때에도 보호휴가를 주도록 하고 이에 따라 휴가중 최초 60일까지는 유급으로 하되, 「남녀고용평등법」에 의하여 국가가 산전후휴가급여 등을 지급한 경우에는 사용자에게 그 금액의 한도 안에서 지급의 책임을 면하게 하려는 것이다.[42] 이에 따라 취업규칙의 기재사항도 출산전후휴가와 육아휴직 등 여성근로자의 모성보호에 관해 추가되었다(당시 조문 제95조 제7의2호).

2008년3월28일 법률 제9038호로 개정된 근기법은 "일·가정 양립(당시 조문 제93조 제8호), "안전과 보건에 관한 사항(당시 조문 제93조 제9호)"은 산업안전에 관한 사항을 추가하였는데, 안전과 보건에 관해서"근로자의 성별·연령 또는 신체적 조건 등의 특성에 따라 사업장 환경의 개선에 관한 사항(당시조문 제93조 제9호의2)"이 신설되었다. 이는 모성보호뿐만 아니라 직장·가정생활의 양립 지원에 관한 사항 및 근로자의 특성을 고려해 작업환경 개선에 관한 사항을 추가하려는 것이 그 주된 목적이다.

(4) 2010년과 2012년 개정근기법에서 명칭의 변화

근기법은 2010년6월4일 법률 제10339호로 개정 되었을 때 제93조 취업규칙의 신고와 관련해서 노동부장관이 고용노동부장관으로 변경되었고, 2012년2월1일 법률 제11270호로 개정 되었을 때 제93조 제5호가 「근로자퇴직급여 보장법」이 개정됨에 따라 퇴직금이 퇴직급여로 변화가 있었으며 제93조 제8호가 산전후휴가가 출산전후휴가로 명칭만 변경되었을 뿐 불이

41) 정영훈, "취업규칙의 불이익변경에 관한 일고찰", 「노동법학」 제31호, 한국노동법학회, 2009.9, 173쪽.
42) 노동부, 앞의 연혁집, 451쪽.

익변경과 관련해서는 눈에 띄는 개정이 발견되지 않는다.

(5) 검토 및 사견

근기법은 1953년에 취업규칙의 작성변경 절차에서 의견청취의 주체로 근로자 과반수대표만 언급하다가 1989년 개정에 이르러서야 불이익변경시 동의주체로 근로자 과반수를 도입하였고, 2005년부터 현재까지 취업규칙의 기재사항의 추가만 있을 뿐 본질적인 변화가 없다. 취업규칙의 기재사항이 근기법뿐만 아니라 관련 개별법령의 개정에 따라 추가되는 것은 당연할 것이나, 불이익변경과 관련해서 최초 개정이 있은 1989년의 입법이 현재에도 실효성이 있는지는 의문이다.

1989년부터 2017년 현재까지 우리의 경제·사회는 급속도로 발전을 거듭하였다. 법적 안정성측면에서 보면, 경제·사회가 변함에 따라 법 개정도 당연히 수반되는 것은 아니지만, 수십 년이 지난 지금 과거 만들어진 법과 지금의 현실과 비교를 해보면 괴리감이 크다. 이런 이유에서 불이익변경과 관련해서 기존의 입장을 유지할지 변화된 사회상을 반영할지 검토해야 할 시점이라 생각한다.

2. 취업규칙 불이익변경법리와 근로자참여제도

(1) 편무성의 극복

취업규칙은 단체협약과 달리 사용자가 작성·변경권을 갖는다. 이러한 한계를 보완하기 위해 근기법은 근로자참여제도를 마련하고 있다. 근기법은 노사대등결정원칙(제4조)에 기초하여 취업규칙을 작성·변경할 때 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 듣도록 하고, 불리하게 변경할 때는 동의를 받도록 규정하고 있다(제94조).

예컨대, 급여규정에서 상여금은 별도의 지침에 따른다고 규정하였으나, 별도의 지침을 규정함이 없이 그동안 상여금 지급율을 500%씩 관행적으로 지급하였다면 동 관행은 근로조건화되었다고 볼 수 있다. 관행으로 근로조건화된 상여금 지급율 등 근로조건을 변경하고자 하는 경우에는 취업규칙의 변경절차를 거쳐야 한다. 따라서 급여규정 변경은 물론 별도지침의 제정 또는 변경 등으로 상여금 지급율 등 주요 근로조건이 변경된다면 이는 취업규칙 변경으로서 근로자에게 유·불리 여부를 판단하여 근로자집단의 의견을 청취하거나 동의를 얻어야 한다고 해석하였다.[43]

43) 근기 68207-1873, 2000.6.20.

이처럼 취업규칙의 작성·변경에 있어 근로자 참여제도를 마련하고 있는 이유는 사용자가 작성·변경권을 갖는 편무성과 일방성을 보완하기 위해서이다. 특히, 집단적 동의제도는 근기법이 갖는 보호법으로서의 성격에 따라, 노사대등결정원칙에 기초하여 근로자의 기득권을 보호하려는데 있다.

(2) 근로자참여방법

1) 근로자참여주체

① 노동조합

사업장에서 '근로자의 과반수'로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합이 의견청취 또는 동의의 주체이다. 따라서 과반수가 아닌 노동조합은 자격이 없으며, 자격있는 노동조합의 의견 또는 동의를 받는 방법은 다음과 같다.

우선, 당해 사업장의 노동조합대표자는 취업규칙의 변경에 대한 의견서 또는 동의서에 서명하면 효력이 발생한다. 다만, 단체협약 또는 노동조합규약 등에 의하여 대표권이 제한되었다고 볼만한 특별한 사정이 있거나,[44] 그러한 행위가 위임되어 있지 않았음을 사용자가 알고 있다는 사실이 입증되면 그렇지 않다. 입증책임은 의견서가 무효라고 주장하는 자에게 있다.[45] 노동조합대의원대회의 위임을 받은 조합운영위원회의 취업규칙변경의견서 또는 동의서는 유효한 것으로 해석된다.[46] 1개의 사업 또는 사업장의 2개 이상의 노동조합이 있고 중복하여 가입한 근로자가 있는 경우에 취업규칙을 변경함에 있어 과반수노동조합 여부는 노동조합마다 가입한 근로자수를 각각 포함시켜 판단한다는 행정해석도 발견된다.[47] 행정해석에 따르면, 근로자 과반수로 조직된 노동조합 유무를 판단할 때 복수노조 사업장에서 각 노동조합에 중복으로 가입한 근로자가 있는 경우 「노동조합 및 노동관계조정법」 시행령 제14조의7 제6항을 적용하여 판단하여야 하는지에 관해 고용노동부는 "근기법은 제94조에서 취업규칙 변경 시 사업 또는 사업장에 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 노동조합, 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수의 의견청취 또는 동의를 얻도록 규정하고 있으나, 2개 이상의 노동조합에 가입한 근로자가 있는 경우의 과반수 노

44) 대법원 1997.5.16. 선고 96다2507 판결. 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있으므로 이와 같은 경우에 있어서도 노동조합의 동의는 법령이나, 단체협약 또는 노동조합의 규약 등에 의하여 조합장의 대표권이 제한되었다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 조합장이 노동조합을 대표하여 하면 되는 것이지 노동조합 소속 근로자의 과반수의 동의를 얻어서 하여야 하는 것은 아니다; 대법원 2000.9.29. 선고 99두10902 판결.
45) 하갑래, 앞의 책 151쪽.
46) 대법원 1984.11.3. 선고 84다카414 판결.
47) 근기-4436, 2016.7.15.

동조합을 판단하는 방법에 대해서는 「노동조합 및 노동관계조정법」과 같이 명시적으로 규정하고 있지는 않으므로 1개의 사업 또는 사업장에 2개 이상의 노동조합이 있고 중복하여 가입한 근로자가 있는 경우에 그 사업장의 취업규칙 변경 시 근로자 과반수로 조직된 노동조합 여부는 노동조합마다 가입한 근로자 수를 각각 세어 판단하여야 한다."는 입장을 밝히고 있다.

다음으로, 초기업노조의 분회는 설립신고가 되어 있거나 취업규칙변경동의권을 위임받은 것으로 볼 수 있어야 의견청취 또는 동의의 주체가 된다.[48] 독자적인 규약 및 집행기관을 가지고 활동하는 지부는 독자적인 단체교섭권 및 단체협약권이 있음을 인정하는 견해를 근거로 하여 설립신고나 위임이 되어 있지 않은 지부에 대해 의견청취 및 동의 주체로 인정하는 의견이 있을 수 있으나 바람직하지 않는다고 생각한다. 왜냐하면 지부는 법적으로 노동조합의 기구에 지나지 않기 때문에 대표권을 주는 것은 부당하게 단결권을 침해할 우려가 있기 때문이다.

마지막으로, 노사협의회는 노동조합과 법적지위가 다르므로 의견청취대상 또는 동의주체인 노동조합으로 볼 수 없다. 취업규칙의 작성·변경에 있어 근로자참여 제도는 강행규정이다. 따라서 이사회, 경영협의회 등 다른 제도로 대체할 수 없다. 정부투자기관과 관련된 법에 '직원의 보수를 이사회가 정한다'라는 규정이 있더라도 이는 그 직원의 기득권이나 기득이익을 박탈하는 결의를 할 수 있다는 취지가 아니므로[49] 근기법 제94조가 적용된다.

② 근로자과반수

근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자과반수의 의견을 듣거나 동의를 받아야 한다. 근기법에서 규정하고 있는 간주근로시간제, 탄력적근로시간제, 선택적근로시간제, 경영상해고 등에 있어 합의 또는 협의의 주체인 근로자대표는 취업규칙의 작성 또는 변경에 있어 의견청취나 동의의 주체가 되지 못한다.

「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」에 의한 근로자위원은 취업규칙 작성 또는 변경에 대한 의견청취 또는 동의의 주체가 아님은 당연하다. 근로자과반수로 취업규칙의 불리한 변경에 대한 동의권을 위임받은 근로자위원은 동의권을 갖는다는 견해가 있으나,[50] 근기법이 명확하게 근로자과반수로 표현하고 있어 비판의 여지가 있다. 근기법이 1953년 제정당시에 "근로자 과반수를 대표하는 자"에서 1989년에"근로자과반수"로 바뀌었기 때문에 이견이 없다고 생각한다.

---

48) 근기 68207-1521, 2001.5.10. 설립신고나 위임이 없이도 분회가 참여주체로 이해될 수 있는 행정해석(노정근1455-3209, 1966.7.7.)은 폐지되었다.
49) 대법원 1991.2.26. 선고 90다15662 판결.
50) 근기 68207-2144, 1999.9.1

③ 이원화된 취업규칙

근로자가 두 개 이상의 집단으로 구분되더라도 같은 조항으로 구성된 하나의 취업규칙을 적용받으면 "전체근로자의 과반수를 대표하는 노동조합이나 전체근로자 과반수"가 취업규칙변경에 있어 의견청취대상 또는 동의주체가 된다. 그러나 취업규칙의 관련 조항에 단서를 붙여 일부근로자에게만 적용시키거나, 처음부터 이원화되어 있으면, 취업규칙의 변경에 있어 의견청취 또는 동의의 대상은 "전체근로자의 과반수를 대표하는 노동조합이나 전체근로자의 과반수"라는 의견과 "변경되는 조항이나 해당 취업규칙의 적용을 받는 근로자집단"이라는 의견으로 나뉜다.

우선, 전체근로자집단동의필요설은[51] "일부근로자에게만 적용되는 취업규칙의 내용을 바꾸더라도 불리한 변경이라면 권한 있는 노동조합이나 전체근로자의 동의를 받아야 한다"고 본다. 이 견해는 취업규칙에 의해 근로조건을 정함에 있어 근로자전체를 대표하는 자의 의견을 전제하는 것이 근기법의 취지라고 본다. 아울러 복수의 취업규칙이 있더라도 전체를 합한 것을 한 개의 취업규칙으로 본다는 점을 그 근거로 삼고 있다.

다음으로, 해당근로자집단동의필요설은[52] "일부근로자에게만 불리하게 변경된다면 변경된 취업규칙을 적용받는 근로자 과반수의 동의를 받아야 한다"고 본다. 이 설의 논리적 근거는 이원적 취업규칙이 인정되는 점, 업무성격이나 근로형태가 현저히 다름에도 불구하고 다수에 의해 소수집단의 의견이 무시될 수 있는 점, 동의를 받지 않고 변경된 취업규칙 내용이 신규근로자에게 효력이 있다는 견해까지 받아들여지는 점 등이다. 이 설은 사업 또는 사업장 내 근로자가 여러 집단으로 구분되어, 근로자집단별로 적용되는 근로조건이나 취업규칙이 달라 노무관리가 별개로 이루어져 있고, 취업규칙의 변경이 일부 근로자집단만을 대상으로 하고 있는 경우에 적용된다.

이와 관해서 대법원은 이원화된 취업규칙을 불리하게 변경함에 있어 동의주체가 되는 근로자집단에 관해서는 특히 실무를 중심으로 상반되는 견해가 혼재되어 왔으나 해당근로자집단동의필요설로 정리하였다. 대법원은[53] 복수의 근로자집단이 하나의 근로조건 체계를 적용받고 있는 상황에서 비록 취업규칙의 불이익변경 시점에는 한 근로자집단만이 직접적인 불이익을 받더라도, 다른 근로자집단에게도 장래에 변경된 취업규칙의 적용이 예상되는 경우에는 그러한 근로자집단을 포함한 전체근로자집단이 동의의 주체가 되며, 직접 불이익을 받는

---

51) 과거의 행정해석(근기 32003-2, 1992.1.4.; 임금 68220-65, 2002.1.30.; 근기 68207-1276, 2003.10.27.; 근기-3936, 2005.7.26. 정규직과 비정규직 관련)의 견해이나, 최근 행정해석(근기-1118, 2009.4.24.)으로 폐지되었다.

52) 임종률, 앞의 책, 359-360쪽; 대법원 1991.9.24. 선고 91다7542 판결; 대법원 1993.1.10. 선고 91다37522 판결; 대법원 1997.9.12. 선고 96다56306 판결; 대법원 2005.11.10. 선고 2005다21494 판결; 대법원 2008.2.29. 선고 2007다85997 판결 등 다수.

53) 대법원 2009.5.28. 선고 2009두2238 판결; 대법원 2009.11.12. 선고 2009두49377 판결 등.

근로자집단 외에 장래에 적용이 예상되는 집단이 없다면, 해당근로자집단만이 동의의 주체가 된다고 본다. 행정해석은 이러한 구분을 두지 않고 현재의 지위를 기준으로 해당근로자 집단을 판단하면서 예외를 인정하지 않고 있다.[54]

그러나 동의주체가 되는 근로자집단에 대해 의견이 정리되었더라도 몇 가지 문제가 제기된다.[55] 첫째,'근로자과반수로 조직된 노동조합'과 '근로자 과반수'의 경우를 같이 취급할 것인지에 대해 의문을 제기할 수 있다. 노동조합의 가입대상이 아닌 근로자의 근로조건을 변경하고자 할 때 자격 있는 노동조합이라도 의견청취나 동의권이 없으며, 해당 비조합원이 그러한 자격을 갖는다는 행정해석이 발견된다. 그러나 노조법에 따른 단체협약효력확장제도의 취지를 고려할 때, 전자에 대해서는 사업 또는 사업장 전체의 근로자를 모집단으로 하여 과반수를 판단하게 되고, 배타적으로 동의권을 갖는다고 보는 것이 타당하다. 따라서 해당근로자집단동의필요설에 대한 논의는 후자에게만 적용된다고 생각한다. 둘째, 해당근로자집단동의필요설을 취하더라도 장래에 적용이 예상되는 경우에는 전체근로자집단의 동의가 필요한지에 대해 판례와 행정해석의 견해가 다르다. 이를 긍정하는 판례의 입장은 현재 뿐 아니라 장래까지를 포함해서 판단하는 것으로 볼 수 있다. 직종이나 근로형태가 변하지 않는 상태에서 지위가 변동하는 경우에는 해당 취업규칙의 구속을 받는 자로 보아야 할 것이다. 따라서 승진 등 하나의 집단에서 지위가 달라지는 경우에는 해당 근로자의 범위에 포함되는 것이 타당하다고 생각한다. 셋째, 의견청취의 경우 전체근로자뿐 아니라 해당근로자도 그 대상이라거나 해당근로자집단동의필요설을 취하면서도 전체근로자집단의 의견청취를 요구하는 것처럼 전체근로자집단의 의견청취는 필요하다고 보는 해석도 있다. 취업규칙의 변경에 있어 근로자참여제도가 중복된 의견수렴절차를 거치도록 하는 것을 상정하고 있지 않다는 점에서 받아들이기 어려운 해석이라고 생각한다.

2) 근로자참여유형

① 의견청취

노동조합이 권한이 있는 경우에는 취업규칙신고서에 의견서를 첨부한다. 이 때 근로자과반수의 의견을 듣는 경우는 집단적으로 회의하는 방법, 근로자에게 취업규칙 안을 배포하여 서명을 받는 방법 등 과반수 의견을 청취하였음을 증명할 수 있는 적절한 방법을 활용한다. 사

54) 근기-1118, 2009.4.24. 기존의 행정해석 중 하나의 사업 내에 정규직근로자와 비정규직근로자에게 별도로 적용되는 취업규칙이 있는데, 그 중 정규직근로자에게만 적용되는 취업규칙을 변경할 경우라도 전체 근로자 과반수의 동의를 받도록 한 것은 폐지하되, 사업장에 전체근로자 과반수대표 노조가 있더라도 "취업규칙 변경 대상이 되는 근로자집단"이 가입할 수 없는 등, 노조가 적용대상 근로자집단 과반수를 대표하고 있다고 볼 수 없는 경우에는 취업규칙 변경 시 의견청취주체가 될 수 없다고 한 것은 유지하였다.

55) 하갑래, 앞의 책, 64쪽.

내회보에 취업규칙 변경내용을 게재하고 게재된 내용에 대해 의견을 제출하도록 하더라도, 근로자 과반수에게 배포되는 등 제도적으로 보장되면 의견을 들은 것으로 해석된다.[56] 의견청취는 동의나 합의를 의미하지는 않는다. 또한, 의견에 구속을 받는 것도 아니다.[57] 설령, 반대의 의사표시를 한 자가 더 많아도 적법하게 의견을 청취하면 의견청취는 효력이 부인되지 않는다. 또한, 노동조합이나 근로자가 의견서에 서명을 하지 않은 경우라고 하더라도, 그 취지와 사유를 첨부하여 신고하게 되며, 의견을 청취한 사실이 객관적으로 입증되면, 그 신고는 수리된다고 보는 행정해석도 발견된다.[58]

의견청취의무의 효력에 대해서는 견해가 나뉜다. 첫째, 효력규정설은[59] 의견청취의무를 정한 근기법 제94조제1항을 효력규정으로 본다. 의견청취가 근로자를 보호하기 위한 강행절차라는 점과 같은 조문의 본문과 단서의 효력을 달리 보는 것은 모순이라는 점이 논리적 근거이다. 둘째, 단속규정설[60]은 의견청위의무를 위반하더라도 취업규칙은 유효하다는 입장으로, 이 견해는 사용자가 의견청취의 내용에 구속 되지 않는다는 데서 논리적 근거를 찾는다는 데 있다. 대법원[61]도 이와 같은 입장을 취하고 있고 불리한 경우가 아닌 한 벌칙 적용은 별론으로 하고 취업규칙의 효력은 유효하다고 하는 단속규정설의 입장이 타당하고 생각한다. 따라서 단체협약으로 취업규칙의 작성·변경에 관하여 노동조합의 동의를 받아야 한다고 규정하고 있더라도 불이익변경의 경우를 제외하고는 노동조합의 동의를 받지 않았다 하여 변경된 취업규칙의 효력을 부정할 수 없다.

비록 불리하지 않은 변경과 단체협약의 동의규정이 있더라도 취업규칙의 변경이 근로자에게 불리하지 않으면, 취업규칙의 작성·변경에 관해 노동조합의 동의를 받아야 한다는 단체규정을 위반해도, 단체협약위반에 대한 책임과 관계없이, 변경된 취업규칙의 효력은 부정되지 않는다.[62] 따라서 취업규칙을 신고할 때 의견서를 미제출하면 500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있으나, 이는 행정감독의 편의를 고려한 단속규정이므로 벌칙과는 관계없이 상위규범에 위배되지 않는 한 취업규칙의 효력은 인정된다고 해석하는 것이 일반적이다.

② 동의

근기법 제94조는 "취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 사용자는 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과

56) 근기 68207-4087, 2001.11.27.
57) 근기 10254-9222, 1991.6.27.
58) 근기 68207-790, 1996.6.11.
59) 이병태, 『최신노동법』 제9판, (주) 중앙경제, 2008, 928쪽.
60) 김유성, 『노동법 Ⅰ』, 법문사, 2005, 205쪽; 임종률, 앞의 책, 358-359쪽; 이상윤, 앞의 책, 419쪽; 김형배, 앞의 책, 303쪽.
61) 대법원 1999.6.22. 선고 98두6647 판결; 대법원 1994.12.23. 선고. 94누3001 판결.
62) 하갑래, 앞의 책, 155쪽.

반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 동의를 받아야 한다."라고 규정하고 있다. 따라서 근로자집단의 동의를 받는 방법은 다음과 같이 정리될 수 있다.

첫째, 과반수로 조직된 노동조합의 경우에는 변경된 취업규칙에 동의한다는 내용의 서면을 첨부하여 서명하면 된다.[63] 법령, 단체협약 또는 노동조합규약 등에 의해 대표권이 제한되었다고 볼만한 사정이 없는 한 노동조합대표가 노동조합을 대표하여 서명하면 되고 별도로 근로자나 조합원 과반수의 동의를 받을 필요가 없다.

둘째, 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자과반수의 집단적의사결정방식 또는 회의방식으로 과반수의 동의를 받는 것이 원칙이다.[64] 근로자수가 많아 한 장소에 모든 근로자를 모아 놓고 회의를 진행하는 것이 어려우면 사업 또는 사업장의 기구별 또는 단위부서별로 사용자측의 개입이나 간섭이 배제된 상태에서 찬반의견을 집약한 후 이를 전체적으로 취합하는 방식도 허용된다.[65] 근로자수가 많다는 이유로 이사회의 심의나 의결로 대체할 수 없다.[66] 동의의 경우에는 의견청취와 달리 취업규칙 변경내용을 개별적으로 공람케 하고 서명을 받는 방법을 부정하는 것이 과거의 판례와 다수설의 태도이다.[67] 그러나 행정해석과 일부 판례처럼[68] 사용자의 개입이나 간섭이 배제된다는 것이 객관적으로 입증된다면 허용될 수 있다고 생각한다. 여기서 사용자측의 간섭·개입이라 함은 근로자들의 자율적이고 집단적인 의사결정을 저해할 만큼 명시 또는 묵시적인 방법으로 동의를 강요하는 경우를 의미하므로, 변경되는 취업규칙의 내용을 근로자들에게 설명하고 홍보하는 행위는 이에 해당하지 않는다.[69]

셋째,[70] 노동조합의 총회나 대의원회 또는 근로자들로부터 취업규칙의 변경에 대한 동의권한을 위임받은 자들이 동의여부를 결정하는 방식도 허용되는 것으로 해석된다. 다만, 이러한

---

63) 대법원 1997.5.16. 선고 96다2507 판결; 대법원 2000.9.29. 선고 99다45376 판결; 대법원 2003.6.13. 선고 2002다65097 판결.

64) 대법원 1977.9.28. 선고 77다681 판결; 대법원 1989.5.9. 선고 88다카4277 판결; 대법원 1977.7.26. 선고 77다355 판결; 대법원 1991.9.24. 선고 91다17542 판결; 대법원 1992.2.25. 선고 91다25055 판결; 대법원 1992.11.10. 선고 92다30566 판결.

65) 대법원 1992.2.25. 선고 91다25055 판결; 대법원 1993.8.24. 선고 93다17898 판결; 대법원 2003.11.14. 선고 2001다18322 판결; 대법원 2004.5.14. 선고 2002다23185 판결; 대법원 2010.1.28. 선고 2009다32522 판결.

66) 대법원 1995.7.11. 선고 93다26168 판결.

67) 대법원 1977.7.26. 선고 77다355 판결; 대법원 1991.3.27. 선고 91다3031 판결; 대법원 1992.11.10. 선고 92다30566 판결; 대법원 1994.6.24. 선고 92다28556 판결; 임종률, 앞의 책, 360쪽; 이상윤, 앞의 책, 419-420쪽; 김형배, 앞의 책, 307쪽.

68) 근기 012512348, 1991.8.28; 대법원 2003.11.14. 선고 2001다18322 판결.

69) 대법원 2003.11.14. 선고 2001다18322 판결; 대법원 2004.5.14. 선고 2002다23185・23192 판결; 대법원 5.3.11. 선고. 2004다54909 판결.

70) 대법원 1992.2.25. 선고 91다25055 판결; 대법원 19931.15 선고 92다39778 판결; 대법원 1993.8.24. 선고. 93다17898 판결.

수임자들이 총회나 대의원회 또는 근로자들로부터 위임을 받지 못한 상태에서 동의권한을 제3자에게 재위임할 수는 없다.

넷째, 그 외의 방법으로 취업규칙에서 규정하고 있는 근로조건보다 비록 불리하게 단체협약을 체결하더라도 동의로 볼 수 있다. 또한 노동위원회의 조정서·중재재정인 경우에도 단체협약과 동일한 효력을 가지므로 동의로 볼 수 있다.[71]

71) 이상윤, 앞의 책, 421쪽.

제3장 취업규칙 불이익변경의 판단

제1절 불이익변경의 판단기초

1. 불이익변경의 개념

근로자집단의 동의는 근기법 제94조 제1항 단서에서"취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우"라고 규정하고 있다. 다시 말해서 불리한 변경이라고 판단되면 근로자 집단의 의사에 구속되는 반면, 근로자에게 불리하지 않으면 의견청취가 가능하다는 결론에 이른다.[72] 비록, 의견청취의 경우 반대한 근로자가 많더라도 취업규칙이 변경되었고, 의견청취 과정을 거치지 않았더라도 벌칙이 적용되는 것은 별론이고 변경된 취업규칙 자체의 효력은 부정되지 않는다. 따라서 불리한 변경인지 여부는 사용자가 취업규칙을 일반적으로 변경할지 여부를 결정짓는 중요한 요소로 작용한다.[73]

불이익변경은 근로자의 기득 권리나 이익을 빼앗아서 근로조건을 저하시키거나 복무규율을 강화하는 것을 말한다.[74] 그러나 불이익여부의 판단을 어떻게 할 것인지에 관해 근기법은 별도의 기준이 마련되어 있지 않다. 복무규율을 강화하는 것은 근로조건을 저하하는 것에 비교해 보면 해석론적으로 완화된 기준이 적용될 수 있다.[75]

우선, 복무규율은 사업장의 질서를 유지하기 위해 해당 근로자에게 가해지는 제한이다. 그러므로 근로자가 다소 불편하더라도 그 자체를 불이익변경으로 볼 수는 없다. 다음으로, 근로조건은 근로자의 수입이나 근로의 양과 질에 영향을 미치기 때문에 명백히 불이익변경이 되기 때문에 취업규칙변경이 근로자집단의 참여제도를 마련하고 있는 목적이기도 하다.

그러나 복무규율과 근로조건은 서로 중첩되거나 영향을 미치는 경우가 많다. 또한 구분이 모호한 경우도 있다. 비록 복무규율에 해당된다고 하더라도 근로조건에 영향을 미치는 것이 있다면 불이익변경의 판단이 될 수 있다. 순수한 의미의 복무규율에 대해서는 불이익변경의 판단 필요성이 포괄적으로 부정될 수 있다.

2. 취업규칙의 작성과 비교

---

72) 하갑래, "취업규칙 불이익변경에 있어 사회통념상 합리성", 「법학논총」 제33권 제2호, 단국대 법학연구소, 2009.12, 771쪽.
73) 이 정 외 2인, 앞의 보고서, 116쪽.
74) 노동법실무연구회, 앞의 책, 462쪽; 김형배, 앞의 책, 308-309쪽; 신권철, 앞의 논문, 37쪽.
75) 하갑래, 앞의 책, 161쪽.

취업규칙을 작성하는 경우에는 근로자집단의 의견청취가 요청된다. 이 때 작성이라 함은 최초의 작성을 말하는 것이 일반적이다. 그런데 기존의 취업규칙에 새 제도를 도입하는 경우 즉 당초에 정해져 있지 않은 제도를 새로이 추가하는 경우와 당초에 정해져 있는 제도를 보충하는 경우도 작성으로 간주되는지에 대해 논란이 있을 수 있다.[76] 특히 불이익신설과 취업규칙의 작성은 구별된다. 취업규칙의 불이익신설은 근로자에게 적용되던 기득권, 기득이익이 존재하는 상황에서 그보다 근로조건을 저하하거나 복무규율을 강화하는 내용이 취업규칙 조항을 신설하는 것인 데 대해여, 취업규칙의 작성은 새로운 취업규칙 조항을 신설한다는 점에서는 동일하나 기득권, 기득이익이 존재하지 않는 사항에 관하여 취업규칙조항을 신설한다는 점에서 양자는 차이가 있다.[77]

이와 관련하여 퇴직금과 관련하여 일정한 근속기간까지만 지급율을 정한 종전의 제도를, 추가로 그 후의 근속기간까지의 지급율을 정하면서 기존근속기간과 추가된 근속기간에 대해 모두 지급율을 기존보다 낮게 조정한 데 대해 기존 근속기간분은 무효이나 추가 근속기간분은 유효하다고 본 판결이 발견된다.[78]

> "회사가 근로자집단의 동의를 받지 않고 근속기간 15년까지의 지급율만을 규정하고 있던 종전의 퇴직금규정을 30년까지의 지급율을 정하는 것으로 수정하면서 그 누진율도 15년까지의 근속기간에 대한 종전 지급율을 인하하고 15년을 초과하는 근속기간에 대하여도 종전의 15년까지의 지급율보다 적은 비율에 의한 금액을 지급하는 것으로 새로이 규정을 둔 경우, 개정 퇴직금규정 중 근속기간 15년까지에 대한 부분은 개정 전 퇴직금규정에 비하여 누진율을 크게 낮춘 것이어서 비록 기초임금의 범위를 넓혔다 하더라도 전체로서 근로자에게 불리하게 변경된 것이라면 그 변경에는 개정 전 규정의 적용을 받고 있던 근로자집단의 동의를 요한다 할 것인데 퇴직금규정의 개정이 그러한 동의를 받지 않고 이루어졌으므로 특별한 사정이 없는 한 무효라 할 것이나, 개정 퇴직금규정 중 15년을 초과하는 근속기간에 대한 부분은 근로기준법의 기준에 적합하고 그보다 유리한 종전 규정이 존재하지 않아 종전의 근로조건을 불이익하게 변경한 것이라고 할 수 없으므로 근로자집단의 동의를 얻거나 의견청취를 하지 않았다 하여도 이를 이유로 그 부분을 무효라 할 수 없고 새로운 퇴직금규정의 제정으로서 유효하다 할 것이어서, 결국 15년까지의 근속기간에 대하여는 개정 전 퇴직금규정이, 15년을 초과하는 근속기간에 대하여는 개정 퇴직금규정이 각 적용된다."

대법원은 후자에 대해서는 기존의 지급율이 없었기 때문에 낮은 지급율을 정하더라도 이는 취업규칙의 작성에 해당된다고 본 것이다. 따라서 작성의 개념을 최초 작성뿐 아니라 새

76) 하갑래, 앞의 책, 157쪽.
77) 노동법실무연구회, 앞의 책, 464쪽.
78) 대법원 1994.6.24. 선고 92다28556 판결.

로운 제도의 도입이나 기존 제도의 보충까지 포함하는 것은 타당해 보이며, 기존제도의 보충의 경우 기득의 권리가 침해받지 않아야 할 것이다.

취업규칙의 불리한 변경은 근로자의 기득 권리나 이익을 박탈하여 근로조건을 낮추거나 복무규율을 강화하는 것을 의미하므로 취업규칙의 내용은 근로조건과 복무규율로 요약될 수 있다. 변경이라 함은 기존의 복무규율이나 근로조건에 대해 그 내용을 바꾸는 것뿐 아니라 삭제 또는 적용 배제를 포함한다. 작성의 경우에도 근로계약 또는 관행으로 이미 적용되고 있는 복무규율이나 근로조건을 바꾼다면 변경에 해당된다.[79]

3. 판단시점과 입증책임

취업규칙의 변경이 불리한지를 판단하는 기준시점은 규칙의 변경이 이루어진 시점이다.[80] 취업규칙이 불리하게 변경되었는지 여부를 입증해야 할 책임은 불리하게 변경되었다고 주장하는 자에게 있다.[81]

근로자의 동의 없이 취업규칙을 불리하게 변경한데 대해 근로자가 이의를 제기치 않다가 10여 년이 경과한 후 이의를 제기했더라도 '금반언의 법리'에 반하지 않는 다는 판결[82]의 입장을 감안할 때 이의제기의 시효는 없는 것으로 볼 수 있다. 이에 대해 대법원은 "근로자 집단의 동의를 거치지 않은 취업규칙의 변경에 대하여 사용자가 그 변경내용을 주지시켰음에도 근로자가 그 내용에 대하여 이의하지 않다가 10여년이 경과한 현재에 이르러 그 개정의 부당함을 다툰다 할지라도 금반언의 법리에 비추어 허용될 수 없는 것은 아니다."라고 판시하였다.

시효가 없다는 것은 퇴직금과 같이 아직 채권으로 발행하지 않은 경우에 해당된다.[83] 따라서 이미 성립된 임금채권은 3년의 시효를 적용 받을 것이며, 시효에 관해 입법적 보완이 요청된다고 생각한다.

---

79) 대법원 1989.5.9. 선고 88다카4277 판결.

80) 대법원 1994.11.18. 선고 93다18938 판결; 대법원 1997.8.26. 선고 96다1726 판결; 대법원 2001.4.24. 선고 99다9370 판결.

81) 서울고판 1978.4.6. 선고 77나2947 판결. 취업규칙의 변경에 의하여 기존근로 조건의 내용을 일방적으로 근로자에게 불이익하게 변경하려면 종전 취업규칙의 적용을 받던 근로자 집단의 과반수 동의를 받아야 하고 그러한 동의가 없는 한 취업규칙 변경의 효력이 없다고 할 것이나 새로운 취업규칙이 종전에 없던 제도를 신설하였다고 하여 반드시 불이익하다고 할 수 없으므로 불이익하게 변경되었다고 주장하는 자는 그 불이익의 정도를 입증하여야 한다.

82) 대법원 1991.9.24. 선고 91다17542 판결.

83) 하갑래, 앞의 책, 170쪽.

제2절 불이익변경의 판단기준

1. 주관적기준과 객관적기준

(1) 견해의 대립

취업규칙은 불리한 변경이라고 판단되면 변경여부가 근로자집단의 의사에 구속되는 반면, 근로자에게 불리하지 않으면 의견청취가 가능하다. 따라서 불리한 변경인지 여부는 사용자가 취업규칙에 대해 일방적으로 변경할 수 있는지 여부를 결정하는 요소가 된다.

취업규칙의 불리한 변경인지를 판단하는 주체는 취업규칙을 적용하는 사업장의 근로자와 그 밖의 제3자 등이 존재할 수 있다. 취업규칙의 변경이 불리한지는 판단주체에 따라 주관적 기준설과 객관적기준설로 의견이 나뉜다.

(2) 주관적기준설

주관적기준설은 근로자가 불리하다고 생각하여 근로자과반수가 반대한 경우에는 불이익변경이라고 본다.[84] 이 견해는 근로조건을 적용받을 근로자가 근로조건이 불리한지 여부를 가장 잘 알 수 있다고 본다. 따라서 해당 근로자들의 과반수가 불리하다고 생각하고, 이 때 반대한 경우에 불이익변경이 된다.

(3) 객관적기준설

객관적기준설은 사회통념상 합리성이 있는지에 따라 판단한다.[85] 취업규칙의 작성·변경권은 사용자에게 있다. 근로자는 작성·변경된 취업규칙에 대해 의견을 제시하거나 동의하는 권한만 있지 대안을 제시할 권한은 없다. 개인적으로는 객관적기준설이 타당하다고 생각한다. 왜냐하면 취업규칙의 변경시 근로자의 의견 또는 동의를 얻도록 하는 것은 사용자의 일방적인 취업규칙 작성·변경권한의 남용을 제한·방지하는 데 그 근본취지가 있으므로 합리적인 취업규칙의 변경조차 금지하는 것은 아니기 때문이다. 따라서 객관적기준에 있어 사회

---

84) 이병태, 앞의 책, 932-933쪽.

85) 이상윤, 앞의 책, 417-418쪽; 임종률, 앞의 책, 361-362쪽; 대법원 1988.5.10. 선고 87다카2853 판결; 대법원 1989.5.9. 선고 88다카4277 판결; 대법원 1993.1.15. 선고 92다39778 판결; 대법원 1994.5.24. 선고 93다14493 판결; 대법원 1997.5.16. 선고 96다2507 판결; 대법원 2001.1.5. 선고 99다70846 판결; 대법원 2002.6.11. 선고 99다70846 판결; 대법원 2010.1.28. 선고 2009다32522 판결; 근기 01254-16545. 1991.11.5.

통념상 합리성에 대하여는 그 변경의 취지와 경위, 불리한 정도, 변경필요 정도, 교섭경위, 동종사업에 대한 일반상황, 업무성질, 취업규칙의 전체적인 체제 등 제반 사정을 종합하여 판단한다.

(4) 검토

사용자가 편무적·일방적으로 작성하는 취업규칙에 대해 근로자가 집단적으로 참여할 수 있도록 제도적으로 보장을 해주어야 한다. 그러나 객관적기준설은 이 목적에 부합하지 않으며, 불리한 변경인지를 판단하는 권한을 사용자에게 부여하고 있어 편무성과 일방성을 치유하기 어렵다고 생각한다. 이러한 점은 결국 분쟁을 촉진하는 요소가 될 수 있으며, 법원에 의해 분쟁이 해결됨으로써 근로조건자율결정원칙에도 크게 벗어날뿐만 아니라, 사회통념상 합리성이라는 모호한 개념에 따라 분쟁이 해결됨으로서 분쟁을 사전에 예방할 수 있는 기준이 확립되지 않는다는 문제점을 안고 있다.

근기법 제94조는 객관적기준설에 따라 해석할 수밖에 없다. 이 견해에 따라 취업규칙의 불리한 변경에 대한 합리성을 불리한 변경과 근로자 과반수 집단 동의라고 하는 2단계를 거쳐 판단하게 되는 중층적인 구조를 가지고 있다. 주관적기준설은 불리한 변경을 판단하는 행위와 동의를 구하는 행위가 구분되지 않는다. 해석론적 관점에서 보면 객관적기준설이 설득력이 있어 보이나, 입법적인 관점에서 보면 비판의 여지가 존재한다고 생각한다.

2. 개별적판단과 종합적판단

(1) 근로조건 기준

1) 견해의 대립

취업규칙을 변경할 때 불리한 요소와 유리한 요소가 섞여 있는 경우가 있다. 이때 종합적으로 판단하여 불리한 요소가 더 많은지를 볼 것인지, 아니면 유리한 요소가 있더라도 불리한 요소가 하나라도 있으면 불리한 요소가 되는 것인지 쟁점으로 부곽된다.

2) 개별적판단설

개별적판단설은 종합적 고려를 부정하고 어느 한 근로조건이라도 불리하면 불이익변경이 되므로 근로자집단의 동의가 필요하다는 입장이다.[86] 이 설은 근로조건을 비교할 수 있는지

의문스럽고, 특정한 근로조건이 불리하게 변경된 만큼 불이익변경으로 보아야 한다고 본다. 또한, 근로자의 권리 보호에 충실한 해석처럼 보인다. 그러나 복수의 근로조건이 명백하게 근로자에게 유리한 경우라도, 동의를 받지 않고 시행했다면 무효가 되므로, 근로자가 유리한 부분을 반납해야 하는 결과를 가져 온다. 그렇다고 해서 동의를 받지 않은 변경 중 불리한 부분만 무효라고 해석하는 것은 동의의 법리에 맞지 않기 때문이다.

3) 종합적판단설

① 적극적 종합고려설

적극적 종합고려설은 종합적 고려의 대상을 '퇴직금과 근로시간'처럼 비교가 가능하지 않은 부분을 포함해서 넓게 보는 입장이다.[87] 이 입장에 따르면 퇴직금제도를 누진제에서 단수제로 변경하였으나 임금인상, 근로시간단축 등 유리한 부분도 있다는 이유로 불리한 변경이 아니라고 보았다. 이 설은 불이익 여부를 판단할 수 없는 내용에 대해서까지 그러한 판단을 인정하면서 동의를 면제시켜 줌으로써 취업규칙 변경 법리의 본질을 침해할 수 있다.

② 소극적 종합고려설

소극적 종합고려설은 종합적 고려의 대상을 대가관계나 연계성 그리고 비교가능성이 있는 근로조건으로 한정하는 입장이다.[88] 그 예로 퇴직금계산의 기초임금과 퇴직금지급률[89], 통상임금 포함임금과 통상임금산정기준시간수[90]등이 발견된다.

대법원 전원합의체 판결에 따라 통상임금이 확대되어 월 통상임금전산기준 시간수를 200시간에서 법정시간수인 243시간으로 변경하는 경우,[91] 단체협약 등에 다른 시간급통상임금이 법적 통상임금 항목 및 법정 월 통상임금산정기준시간수로 계산한 시간급통상임금보다 낮지 않으면서 변경 후의 시간급통상임금이 저하되지 않는다면 취업규칙 불이익변경에 해당하지 않는 것으로 본다. 이때 대가 관계나 연계성 그리고 비교 가능한 근로조건끼리는 산술적인 계산 등을 통해 비교가 가능하므로 이 설의 입장이 타당하다고 생각한다.

---

86) 임종률, 앞의 책, 361-362쪽; 김지형, 『노동법해설』, 청출어람, 1993, 314쪽.
87) 대법원 1984.11.13. 선고 54다카414 판결.
88) 김유성, 앞의 책, 206쪽; 대법원 2001.4.24. 선고 99다9370 판결; 대법원 1992.2.28. 선고 91다30828 판결; 대법원 1987.2.24. 선고 84다카1409 판결; 대법원 1997.8.26. 선고 96다1726 판결; 대법원 1995.3.10. 선고 94다18072 판결; 법무 811-19135, 19802.2.
89) 대법원 1995.3.10. 선고 94다18072 판결.
90) 근로개선정책과-7283. 2014.12.16.
91) 근로개선정책과-7283. 2014.12.16.

4) 검토

종합적판단은 포괄적인 의미를 가지고 있다. 따라서 취업규칙의 변경내용이 어떠한 구조를 갖는지에 대해서도 적용될 수 있고, 취업규칙을 변경할 때 근로자에게 불리한 요소와 유리한 요소가 혼재되어 있는 경우 유리한 요소가 더 많은지를 볼 것인지, 아니면 불리한 요소가 하나라도 있으면 불이익변경이 되는지에 대해 의견의 차이가 존재할 수 있다. 이처럼 종합적판단을 둘러싸고 의견의 차이가 존재하는 것은, 불이익변경 여부의 판단이 객관적기준설 에 따라 이루어지기 때문이다.

따라서 입법적인 보완을 검토할 때 비교 가능한 요소를 종합하는 취지를 명시하는 것도 고려대상이 될 수 있다.

(2) 적용대상 근로자 기준

대법원은 취업규칙의 변경이 일부의 근로자에게는 유리하고 다른 근로자에게는 불리하면 불이익변경에 준하여 해석한다는 입장이다.[92] 그 예로 일반직직원은 55세에서 58세로 관리직직원은 60세에서 58세로 정년을 변경하기 위해서는 전체 직원에게 불이익하므로 전체직원을 대상으로 동의를 받아야 한다. 취업규칙이 근로자에게 불리하게 변경된 것인지를 판단함에 있어서는 “종다수의 원칙”과 같은 종합적판단기준을 사용하는 것은 타당하지 못하며 개별적판단원칙을 적용하여 적용대상근로자 중 한 사람에게라도 불리하다고 판단되면 집단적동의가 필요하다.

92) 대법원 1993.12.28. 선고 92다50416 판결; 대법원 1995.3.10. 선고 94다18072 판결; 대법원 1995.3.10. 선고 94다18072 판결; 대법원 1997.8.26. 선고 1726 판결; 대법원 1997.8.26. 선고 96다1726 판결; 대법원 2009.5.28. 선고 2009두2238 판결.

제4장 불이익변경에 있어 근로자집단 동의의 한계

제1절 사회통념상 합리성법리와 동의불필요

1. 사회통념상 합리성법리 형성

취업규칙을 변경함에 있어 사회통념상 합리성을 전제로 근로자집단의 참여를 소극적으로 판단하는 법리가 판례를 중심으로 형성되고 있다.[93] 이러한 판단들은 사회통념상 합리성이 인정되면 불이익변경이 아니라고 보다가, 최근에는 근로자에게 불리하게 변경된 취업규칙은 원칙적으로 근로자의 동의를 받아야 하지만 사회통념상 합리성이 인정되면 근로자의 동의가 없더라도 취업규칙의 변경이 유효하다는 취지로 변화하는 보습을 보여주고 있다.

취업규칙을 불리하게 변경할 때 집단적 동의를 받도록 한 것은 사용자의 일방적인 변경을 방지하고 근로자의 기득권을 보호하기 위함이다.[94] 그러나 대법원은 경영악화 등 여러 가지 사정상 취업규칙의 변경이 반드시 필요하고 그 내용이 합리적이더라도, 집단적동의를 받지 못하여 경영권이 침해될 수 있다는 관점으로 법리가 형성되고 있다.

2. 합리성과 불이익변경

(1) 개관

신설 규정이 사회통념상 합리성을 갖는다면 불이익변경으로 보지 않는다.[95] '사회통념상 합리성'은 변경내용이 동종업계 등을 고려할 때 합리적이고, 궁극적으로 근로조건을 저하시키지 않으며, 신설되는 제도로 인해 바로 불이익을 받는 사람이 현실적으로 없고, 특정한 근로자를 퇴직시키는 등 불이익을 주려는 목적이 아니라면 인정될 수 있다. 판례와 행적해석은 불이익변경 여부를 판단하는 기준으로서의 합리성에 대해 다양한 견해를 보여주고 있는데, 사건의 성격에 따라 분류하면 '복무규율에 관한 사항'과'근로조건에 관한 사항'으로 구분된다.

---

93) 박종희, "임금피크제와 취업규칙 변경 절차에 관한 법적 검토", 「노동법포럼」 제15호, 노동법이론실무학회, 2015.7, 32쪽.

94) 강성태, "노동개혁을 위한 노동법의 과제 - 근로시간·해고·취업규칙의 개정론을 중심으로 -", 「노동법학」 제56호, 한국노동법학회, 2015.12, 105쪽.

95) 대법원 1978.9.12. 선고 78다1046 판결; 대법원 1989.5.9. 선고 88다카4277 판결.

(2) 복무규율에 관한사항

1) 인사·노무·조직

인사·노무·조직관리에 관한 사항은 포괄적으로 불이익변경이 아닌 것으로 본다. 구체적으로는 인사고과, 평가·시험, 연수·승진 등 인사관리를 위한 제도를 강화하거나 신설하는 것은 사회통념상 합리성이 인정된다.[96] 인사·노무관리에 필요한 사항은 경영·인사권의 본질적인 사항이다. 행정해석은 취업규칙에 기재되더라도 작성 및 신고의 대상이 되는 취업규칙의 내용이 아니며 신설이나 강화는 사용자의 권한에 속한다고 해석한다.[97]

2) 정원조정·직제개편

기구별·직급별 정원조정이나 직제개편은 포괄적으로 불이익변경이 아니라고 해석되는데,[98] 경영권에 속하는 사항이고 취업규칙의 본질적인 내용이 아니라는 것이 그 이유이다.

구체적으로 직제변경으로 인해 전체 또는 일부 근로자의 직급이 하향 조정되거나 기존의 직급보다 낮게 신설된 직급에 이전 직급의 자를 배치함으로써 기존의 근로조건이 저항된다면 불이익변경에 해당된다.[99] 인사규정을 특정한 직위를 담당할 수 있는 종전의 직무등급보다 연봉이 낮은 직부등급을 배치할 수 있도록 개정하고, 회사가 결정한 업적부진, 능력부족 등 사유에 해당한다면, 징계절차 없이 신설되어진 직무등급으로 발령하여 임금이 삭감되었다면 불이익변경에 해당된다.

또한, 정원조정이나 직제개편 자체는 노동의 강도가 높아지거나 양이 많아질 수 있으나, 개연성이 존재할 수 있다는 사정만으로 불이익변경이라고 보기는 어렵다. 정원조정이나 직제개편으로 초래되는 근로연장시간, 임금삭감, 직급강등 등이 불이익변경이 된다. 따라서 직급강등 등이 취업규칙에 규정된 것이 아닌 상태에서 정원조정이나 직제개편의 결과로 부수적으로 이루어진다면, 이는 부당한 인사조치의 문제가 된다고 생각한다. 아울러 직급조정이 전체적으로 이루어지면서 임금 등의 근로조건이 저하되지 않는다면 불이익변경으로 보기 어려울 것이다.

3) 기존제도 구체화

---

96) 근기 01254-11010, 1987.7.9.
97) 근기 68207-352, 2003.3.26.
98) 근로조건지도과-1153, 2008.4.29.
99) 근로조건지도과-1153, 2008.4.29; 근로기준팀-750, 2006.2.16.

기존의 제도에 대해 본질을 바꾸지 않으면서 절차나 방법을 구체화하고 합리화하는 것은 불이익변경이 아니다. 포괄적·추상적으로 규정되어 있던 징계의 사유·종류 등을 세목화하여 상세히 규정하는 것은 징계양정을 높이거나 징계의 요건을 완화하는 것이 아닌 한 불이익변경으로 보지 않는 것으로 해석된다.[100] 따라서 인사규정 중 해직사유인 "금고 이상의 형의 집행을 받게 되었을 때"라는 요건에 대하여 "금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예기간 중에 있는 자"를 추가하여 변경한 것은 규정의 정비에 지나지 않는다.

취업규칙에 이미 변상책임이 규정되어 있는 상황에서 세부적인 변상절차를 제정하는 것은 불이익변경이 아니라고 본 행정해석[101]이나 해고 조항을 근거로 통상해고 또는 저성과개선 프로그램을 신설하는 것에 대해 불이익변경이 아니라는 대법원 견해[102]도 발견된다.

4) 합리적인 제도신설

제도를 신설하는 경우 사회통념상 합리성이 있으면, 불이익변경이 아니다. 대법원[103]은 징계규정 자체를 신설하거나 보완 또는 변경하는 것은 그 내용이 합리적인 경우 불이익변경으로 보지 않을 수 있으나, 자의적인 징계규정신설은 불이익변경이라고 본다. 징계규정에 "무계출 또는 부득이한 사유가 없는 결근이 7일을 초과한 경우 자동 퇴출된다."는 조항을 신설한 것에 대해 자동적으로 면직하는 것은 불이익신설이라고 보았다. 이 경우 불이익신설로 본 이유는 자동퇴출과 관련된 부분으로, 자동퇴출이 아닌 해고로 제도를 설계한다면 불이익신설로 보기 어렵다.

반면 행정해석은[104] 해임과 정직 사이에 강등이라는 징계유형을 신설하는 것은 징계 사이의 효력의 차이를 완화하는 것으로 불이익 신설이 아니라고 해석한다. 행정해석에 따르면 그 양정 사이에 형평성을 마련한 점, 비위의 유형을 구체화 또는 세분화한 점, 비위의 경중에 따라 합리적으로 조정한 점 등에 비추어 보면 근로자에게 불리하게 변경된 것으로 볼 수 없다고 보는 입장이다.

(3) 근로조건에 관한사항

1) 기득권의 침해

---

100) 대법원 1999.6.22. 선고 98두6647 판결; 대법원 1988.5.10. 선고 87다카2583 판결.
101) 근기 01254-10917, 1991.727.
102) 대법원 2012.5.29. 선고 2011두4760 판결.
103) 대법원 1989.5.9. 선고 88다카4277 판결.
104) 근로기준과-47, 2010.7.8.

근로자들의 기득권을 해치지 않으면 불이익 변경으로 인정되지 않을 수 있다고 생각한다. 성과급제도를 도입함에 있어 어느 한 근로자라도 임금이 저하 된다면 불이익변경이나,[105] 그렇지 않다면 합리성을 인정받을 수 있다. '수당을 신설하면서 퇴직금산정기초에서 제외'하는 것[106]은 퇴직금액의 변동 없이 임금을 올림으로 불리한 변경으로 보기 어렵다. 반면에, 근로형태를 통상근로에서 교대근로로 변경하는 것[107]은 불이익변경으로 보는 것이 행정해석의 견해이다.

2) 제도의 본질

제도의 본질을 해치지 않는 경우가 있다. 우선, 상여금제도가 고정적상여금을 결근일수비율로 삭감하는 것처럼 명백히 근로자에게 불리하게 변경됨에도 불구하고 합리성을 들어 불이익변경으로 보지 않는 것이 대법원의 견해이다.[108] 이에 따르면 성과와 관계없이 정기적·일률적으로 지급되는 상여금을 결근일수비율에 따라 삭감토록 하는 것은 불이익변경이라고 볼 수 없으나, 결근일수비율 이상을 삭감하는 것은 불이익변경이다. 이처럼 명백히 금품수입의 상실을 초래할 수 있는 제도변경이 불이익변경이 아니라고 보는 것은 의문의 여지를 남긴다. 따라서 같은 결과를 도출하더라도 불이익변경을 부정하는 법리보다는 동의를 면제하는 법리로 접근이 되어야 할 것이다.

기존의 정년을 단축하면 불이익변경이다.[109] 정년을 신설하는 것은 고용시간을 단축함으로써 근로자에게 불리하게 작용한다. 이러한 변경도 그 자체로는 합리성을 인정할 수 있으므로 기존 근로자의 기득권을 침해하지 않는 한 불이익변경이 아니라고 해석된다.[110] 그러나 연령차별금지의 정신 및 고령자의 고용을 촉진할 필요성을 감안할 때 정년이 없는 상태에서 정년을 신설하는데 대해 합리성을 인정하면서 불이익변경이 아니라고 보는 것은 타당하지 않는 것으로 해석된다.[111] 특히 신설되는 정년에 도달한 근로자가 이미 존재하거나 동종업계와 비교할 때 정년이 현격하게 낮은 경우에는 명확한 불이익변경이다. 정년연장은 인사적체를 초래한다는 이유로 근로자집단의 동의를 받지 못해도 근로자의 생활을 더 보호할 수 있다는 점을 감안할 때 불이익변경으로 보기 어렵다고 생각 한다. 사업장에서 이러한 갈등이 발생하는 이유는 불이익변경에 대한 판단을 객관적기준설에 의존하고 있기 때문으로 보인다. 주관

105) 근기 68207-2775, 2002.8.20.
106) 대법원 1991.4.9. 선고 90다16245 판결; 대법원 1997.8.26. 선고 96다1726 판결.
107) 근기 68207-935, 2003.7.23.
108) 대법원 1991.8.13. 선고 91다3642 판결.
109) 근로기준과-4310, 2004.8.17.
110) 대법원 1978.9.12. 선고 78다1046 판결; 서울행정법원 2011.9.22. 선고 2011구합6875 판결.
111) 대법원 1997.5.16. 선고 96다2507판결.

적기준설을 따르면 근로자의 의견수렴과정에서 불이익여부가 판명되므로 이러한 문제가 발생하기 어렵다. 정년제도를 도입하면서 '신규입사자에게만 적용'하면 불이익변경으로 보지 않는다.[112] '정년을 연장하면서 연장기간에 대해서만 임금을 저하'해도 퇴직급여에 영향을 미칠 수 있으므로 불이익변경이 될 수 있다.[113] 경영위기극복 등을 위해 특별협약의 형식으로 한시적인 정년단축을 통해 조기퇴직시키는 것은 노동조합의 목적이나 근로조건 불이익변경의 한계를 벗어난 것으로서 무효가 되어 사실상 해고에 해당한다는 견해가 있다.[114]

3) 근로조건 합리화

근로조건을 합법화하거나 합리화하는 경우는 불이익변경으로 보지 않는 경우가 있는데, 우선 교대제 근로와 관련해서 근기법 제93조는 "교대근로에 관한 사항"을 취업규칙의 기재사항으로 규정하고 있다. 이를 감안할 때 사용자가 교대제를 변경하기 위해서는 취업규칙변경절차를 거쳐야 한다.[115] 교대제근로로 변경하는 것은 통상의 근로보다 생활리듬 주기의 파괴 등에 비추어 보면 근로자에게 불이익한 변경에 해당된다고 생각된다. 반면, 교대제 근로형태를 '3조 3교대제'에서 '4조 3교대제'로 변경하게 되면, 실근로시간의 단축으로 연장근로가 줄게 되어 '3조 3교대제' 아래에서 지급받던 연장근로수당이 감소하게 된다. 그러나 소정근로시간이 단축되고, 소정근로에 대한 기존임금은 감소되지 않는다면 불이익변경에 해당하지 않는다.[116] 행정해석은 취업규칙에 정해진 전보규정에 따라 교대제근무자를 주간근로자로 배치전환하면 별도의 수당이 발생하지 않는데 따른 금전적 손실이 있어도 불이익한 처분이 아닌 것으로 보고 있다.[117]

다음으로 그 밖의 근로조건과 관련해서 연장근로를 축소 또는 폐지함으로써 연장근로수당을 줄이거나,[118] 일정한 시간분의 연장근로를 고정적으로 수행하는 것으로 보는 포괄임금제를 폐지하고 실제 연장근로시간을 기준으로 수당을 지급하는 것을 불이익변경으로 볼 수 없는 것이 행정해석의 견해이다.[119]

(4) 검토

---

112) 대법원 1994.5.24. 선고 93다463841 판결; 근로기준과-1296, 2004.3.16; 근로기준팀-194, 2006.1.10.
113) 근기 68207-2163, 2002.6.8.
114) 대법원 2011.7.28. 선고 2009두7790 판결.
115) 근기 68207-1732, 1994.11.4.
116) 근기 68207-1732, 1994.11.4.
117) 근기 68207-691, 2003.6.11.
118) 근기 68207-286, 2003.3.13.
119) 근로개선정책과-369, 2011.3.18.

복무규율에 관한 사항은 취업규칙변경에 대한 합리성을 인정받는 것이 일반적이다. 반면, 근로조건에 대한 사회통념상 합리성을 이유로 불이익변경으로 보지 않는 판례와 행정해석들이 발견되기도 한다. 이러한 해석들은 실태가 어떠한지에 따라 다양한 모습을 보여주면서 이를 통해 법리를 형성해 오고 있다. 기왕에 취업규칙에 대한 여러 가지 문제점이 노출되었다면, 새로운 판례나 행정해석을 기다릴 것이 아니라 입법자가 입법을 통해 명확하게 하는 것이 바람직해 보인다고 생각한다.

3. 합리성과 동의불필요

(1) 동의 불가능

사용자측이 취업규칙의 불이익변경에 대하여 근로자들의 동의를 받는 것조차 불가능하다고 볼 수밖에 없는 사회통념상 합리성이 인정되면 동의를 받지 않아도 효력을 갖는다.[120] 다만, 그 불가능에 대해서는 사용자에게 입증책임이 있다.

(2) 일반적 합리성

1) 원칙적 판단기준

원칙적 판단은 취업규칙의 변경이 당시 상황을 근거로 판단한다. 이 판단기준에 따르면 그 필요성 및 내용이 근로자가 입게 될 불리함을 고려해도 변경된 조항의 법적 규범성을 인정할 수 있을 정도로 사회통념상 합리성이 있다면, 집단적동의가 없다는 이유만으로 그 적용을 부정할 수 없다는 것을 근거로 한다.[121]

2) 부가적 판단기준

부가적판단은 사회통념상 합리성에 대해 취업규칙의 변경이 근로자에게 불리한 정도, 변경된 취업규칙 내용의 상당성, 변경에 대신해서 행한 조치를 포함한 다른 근로조건의 개선상황, 노동조합 등과의 교섭경위 및 노동조합이나 다른 근로자의 반응, 같은 사례에 관한 일반적인 정황 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. 근로자집단의 동의를 대신할 만큼 사회통념상 합리성이 있는지는 개정 당시의 상황을 근거로 한다.[122]

---

120) 대법원 1993.1.15. 선고 92다39778판결.
121) 하갑래, 앞의 책, 166쪽.
122) 대법원 2001.1.15. 선고 99다70846 판결; 대법원 2002.6.11. 선고 2001다16722 판결; 대법원

그 예로 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」(이하 "연령법"이라 한다)의 입법취지를 살펴보면, 근로자의 고용안정을 위하여 정년60세를 보장하는 것으로 임금피크제 도입 등 임금체계 개편을 통하여 정년 60세가 실질적으로 보장되어야 함을 감안할 때 우선, 취업규칙의 변경으로 근로자가 입게 되는 불이익의 정도는 임금 감액 시기 및 정도 등이 중요한 판단 요소이나 정년연장으로 사실상 고용기간 연장이라는 이익을 얻는 점이 있으므로, 기존 정년 시점 이후 임금피크제를 도입한 경우에도 고령자고용촉진법 입법취지를 형해화할 정도의 낮은 임금 및 근로조건 변경 등이 아닌 임금 감액이 이루어진 경우 불이익이 크다고 보기 어렵다고 할 것이다.[123]

둘째, 사용자측의 취업규칙변경 필요성의 내용과 정도는 연령법 개정에 따라 60세 정년 보장 법제화가 도입 되었고 임금피크제를 포함한 임금체계를 개편해야 할 의무를 노사 모두에게 부여하고 있으므로, 현재 기업의 경영상황, 인력구조, 평균근속년수 등을 고려할 때 개별기업은 물론 전체 노동시장에서 고용안정, 신규일자리 창출 여력 확보, 인건비 부담과 조화 등을 위한 것으로 볼 수 있다. 따라서 개별기업의 구체적 사정을 고려하여 합리적 수준에서 임금피크제 등 임금체계개편이 이루어지는 경우 변경의 필요성은 인정될 수 있다.[124]

셋째, 변경된 취업규칙 내용의 상당성과 관련해서는 불이익 외에 경과조치 등을 고려하여 내용의 상당성 여부를 판단하여야 한다. 임금피크제의 경우 임금피크를 적용하는 연령, 변경 후 임금 수준이 비슷한 규모의 동종 다른 기업 또는 사회 일반적으로 기대되는 합리적인 임금수준과 비교하여 저하되지 않은 경우에는 상당성이 인정될 수 있을 것이다. 특히, 일정시점부터 감액하여 임금 감소에 따른 생활상의 불이익을 최소화할 수 있다면 해당 취업규칙 변경 내용이 상당하다고 볼 수 있다.[125]

넷째, 대상 조치 등을 포함한 여타의 근로조건의 개선 여부는 임금피크제 등의 도입에 대응하는 보상 등 다양한 수단을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이때 추가적으로 근로시간 단축, 업무의 조정, 복리후생 제도의 확대 등 제반의 개선 상황을 고려하여야 한다.[126]

2004.5.14. 선고 2002다23185·23192 판결; 대법원 2004.7.22. 선고 2002다57362 판결; 대법원 2009.6.11. 선고 2007도3037 판결; 대법원 2010.1.28. 선고 2009다32362 판결; 대법원 2015.8.13. 선고 2012다43522 판결.

123) 서울중앙지방법원 2008.8.1. 선고 2007가합11716 판결(항소기간 도과로 확정). 임금피크제 실시로 인하여 비록 정년이 58세에서 59까지 연장되었지만, 근로자들은 만 55세가 도래하는 연도의 3.1.부터 정년에 이르기까지 임금이 해마다 70%,60%, 40%, 40%로 순차 감액 되어, 종래 만 58세까지 3년간 지급받던 임금(연봉의 300%)에 비하여 임금피크제 시행이후 만 55세부터 정년인 59세까지 4년간 그보다 훨씬 감액된 임금{연봉의 210% (70%+60%+40%+40%)}을 지급받게 되었으므로 전체적으로 보아 임금피크제의 실시로 인하여 근로조건이 불이익하게 변경된 것이다.

124) 고용노동부, 「직무능력과 성과 중심의 인력운영과 취업규칙 지침 설명자료」, 고용노동부, 2016, 23쪽.

125) 하갑래, 앞의 책, 166쪽; 박종희, 앞의 논문, 47-48쪽.

126) 고용노동부, 앞의 자료, 23쪽.

다섯째, 노동조합 등과의 충분한 협의 노력과 관련해서는 취업규칙 변경 시 노사의 교섭 상항, 협의 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 다만, 실질적 교섭과 협력이 이루어져야 할 것이다. 사용자가 취업규칙의 변경권한이 있다는 이유로 연령법의 취지를 도외시 한 채 일방적으로 변경하거나 형식적으로 협의를 거친 경우에는 합리성이 인정되지 않는다. 연령법은 "사업주와 함께 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 취업규칙 불이익변경 절차와 달리 근로자 과반수가 아닌 근로자대표(근로자과반수를 대표하는 자)와 임금체계 개편을 위한 조치를 하도록 규정"하고 있다. 따라서 사용자가 근로자의 의견을 충분히 청취하고 근로자로부터 임금체계개편 등에 관한 협의 권한을 위임받은 근로자대표와 성실히 협의한 경우 사회통념상 합리성 인정 시 고려 요소가 될 수 있다고 생각한다. 근로자대표와의 임금체계 개편 합의가 취업규칙 불이익 변경으로 인정 될 수 있는지에 대해서는 사용자가 임금체계 개편을 위해 상당한 수준의 협의 노력을 했음에도 근로자 또는 노동조합 측이 교섭 자체에 무조건 응하지 않거나 합리적 대안 제시도 없이 반대 하는 등 협의가 이루어지지 않는 경우에는 사용자측에게 요구되는 충분한 협의 노력 의무가 이행된 것으로 볼 수 있어 사회통념상 합리성을 인정할 수 있는 요소가 될 수 있다.[127]

마지막으로, 동종 사항에 관한 국내 일반적인 상황 등은 사회통념상 합리성 여부를 판단함에 있어 개별적 기업 상황을 고려하여야 한다. 그뿐만 아니라 임금피크제 도입 등에 따른 취업규칙 변경 내용과 관련하여 지역 내 동종 업계 등의 임금감액 비율, 대상 조치, 교섭 및 합의 경향 등을 고려 종합적으로 판단하여야 한다.[128]

3) 포함범위

일반적합리성은 근로조건 통일과 정부방침 및 공익으로 나누어 설명 할 수 있다. 우선, 전자는 계열사의 다른 회사와 근로조건의 수준을 맞추려는 의도만으로는 합리성을 인정받지 못한다. 다만, 회사합병 등으로 퇴직급여규정을 하나로 통일하는 과정에서 과반수 근로자 집단의 동의 없이 일부 사업장 근로자들에게 불이익한 내용으로 변경한 것을 인정한 사례가 발견된다.[129]

다음으로, 후자는 정부방침과 공익에 있어 근로조건의 하향조정이 '정부의 개정압박', '공무원급여수준과의 형평' 등을 이유로 한 정부방침에 따라 이루어지더라도, 동의를 받지 않아도 될 만한 사회통념상 합리성이 인정되지 않는 것이 일반적이다.[130] 이러한 입장은

127) 고용노동부, 앞의 자료, 24쪽.
128) 하갑래, 앞의 책, 166쪽; 박종희, 앞의 논문, 48쪽.
129) 대법원 2000.9.29 선고 99다45376 판결; 대법원 2001.1.5. 선고 99다70846 판결.
130) 대법원 1993.1.26. 선고 92다48326 판결; 대법원 1990.3.13 선고 89다카24780 판결; 대법원 1992.11.27. 선고 92다32357 판결; 대법원 199.5.14 선고 93다1893 판결; 대법원 1993.9.14. 선고 92다

“정부기관의 산하기관으로서 정관에 급여규정 등의 제정 및 개폐에 관해 감독관청에게 보고하도록 되어 있는 점”을 다른 요인과 함께 종합적으로 고려하여 불이익변경에 합리성을 인정하는 방향으로 판례가 변화하는 모습을 보여주고 있다. 해당 판례는 정부의 산하기관이라는 점 외에 여러 요인을 복합적으로 고려하고 있어 일반화시키는데 한계가 있다.

(3) 검토

일본에서 시작된 판례법리는 한국에서도 자리를 잡아가고 있는데, 근로조건이 명백하게 불리해지더라도 사회통념상 합리성이 있는 경우에 동의를 받지 않아도 되는 법리를 형성하고 있다. 일본은 「노동기준법」에 취업규칙의 작성 또는 변경 절차에 대해 근로자대표의 의견청취 조항만을 둔 상태에서, 판례를 통해 편무성의 단점을 해소하기 위한 법리가 발전되어 왔으며,[131] 이러한 법리는 「노동계약법」에 반영되어 있다. 일본에서는 취업규칙이 원칙적으로 그에 동의한 사람에게만 적용된다. 이 경우 취업규칙은 그 통일성, 집단성 등이 훼손된다. 그래서 사회통념상 합리성이 있으면 동의를 받지 않는 사람에게도 적용된다는 법리로 발전되었다.

우리나라는 1989년 개정 근기법부터 취업규칙의 불이익변경에 대해 집단적동의를 효력요건으로 법에 명시하고 있다. 따라서 취업규칙의 불이익 변경에 대해 법적근거 없이 합리성법리를 적용하여 근로자집단의 동의를 면제시켜주는 것은 타당해 보이지 않는다. 이러한 근기법의 동의 규정을 배제하는 효과를 가질 수 있기 때문에 엄격한 해석을 요구하는 판례가 발견되며, 해당 법리는 매우 예외적인 경우에 적용될 수 있을 것이다. 사회통념상 합리성법리는, 취업규칙의 규범성에 제한을 가하는 의미를 가지므로, 해석보다는 입법에 의해 제도화되는 것이 바람직할 것이다.

제2절 동의의 효력

1. 효력의 일반원칙

근로자에게 불리하게 취업규칙을 변경하는 경우 근로자집단의 동의가 없더라도 전체 취업규칙이 무효가 되는 것이 아니고 변경된 부분만 전체근로자에게 효력이 없게 되어 변경전의 취업규칙이 적용된다.[132] 취업규칙을 불리하게 변경함에 있어 근로자집단의 동의를 받지 못

45490 판결; 대법원 1994.10.14. 선고 94다25322 판결.

131) 김 철, “취업규칙제도의 비교법적 일고찰”, 「경희법학」 제45권 제4호, 경희대 법학연구소, 2010. 12, 228쪽.

한 이상 개인적으로 동의한 근로자에게도 효력이 발생하지 않으며,[133] 근로자집단의 동의를 받으면 개인적으로 반대하더라도 변경의 효력이 발생한다.[134] 따라서 근로자집단의 동의를 받지 못하면 근로자에게 유리한 부분까지 포함한 변경규정 모두가 무효가 될 것이다.

2. 불이익변경과 사정변경

취업규칙을 변경함에 있어서 집단적동의를 얻지 못하더라도 그 후의 사정변경에 의해 근로자들이 이미 획득한 이익을 침해하지 않게 되면, 기존 근로자들에게 적용될 취업규칙은 개정된 취업규칙이 된다는 판례가 있다.[135] 이 판례는 종전에 변경된 취업규칙의 효력을 분석함에 있어 근로자집단의 동의여부를 판단의 기준으로 삼지 않고 불이익변경 문제로 접근한 것으로 평가할 수 있다.[136] 다만, 사정변경이 있어 근로자에게 유리하게 되기까지 동의를 얻지 못해 무효인 취업규칙이 계속 존재한다는 논리적 모순이 존재할 수 있다.

3. 신규입사자

(1) 견해의 대립

취업규칙의 불이익변경이 동의를 받지 못한 경우 신규 및 재입사 근로자에 대해 효력이 있는지를 둘러싸고 의견이 나뉜다.

우선, 상대적유효설은 근로자집단의 동의 없이 불리하게 변경된 취업규칙이 신규 근로자에게도 효력이 있는 견해이다.[137] 이 견해는 첫째, 취업규칙 작성·변경권이 사용자에게 있는 점, 둘째, 기존근로자의 기득권침해가 없는 점, 셋째, 신규근로자가 변경된 취업규칙을 수용하고 입사하는 점을 근거로 삼는다. 이 견해는 변경된 취업규칙이 법규범적효력을 갖고 종전의 취업규칙이 기존근로자의 기득권을 보장하는 범위 내에서만 효력이 있으므로 하나의 사업에 2개의 취업규칙을 행하므로 그 부분에 한해 효력이 없어 그들에게는 종전제도를 적용하는 것이므로 '퇴직금제도 차등금지조항'에도 위반되지 않는다고 본다. 상대적유효설은 개정된 보수규정이 종전의 근로자에 대한 관계에서는 무효라 하더라도 임용기간만료 후에

132) 대법원 1997.8.26. 선고 96다1726 판결.
133) 대법원 1977.7.26. 선고 2007다85996 판결; 대법원 1991.3.27. 선고 91다3031 판결; 대법원 1991.9.24. 선고 91다17542 판결; 대법원 1992.12.8. 선고 91다38174 판결.
134) 대법원 2008.2.29. 선고 2007다85997 판결.
135) 대법원 1997.8.26. 선고 96다1726 판결.
136) 하갑래. 앞의 논문, 780쪽.
137) 대법원(全) 1992.12.22. 선고 91다45165 판결; 이상윤, 앞의 책, 422쪽; 임종률, 앞의 책, 364쪽; 김형배, 앞의 책, 311-312쪽.

재임용계약을 체결한 자에 대해 적용될 수 있다.[138]

다음으로 절대적무효설은 취업규칙이 근로자의 동의없이 불리하게 변경되면 신규입사자를 포함한 모든 근로자에게 효력이 없는 견해이다.[139] 이 견해는 첫째, 집단적동의를 받지 않는 취업규칙은 개인적으로 동의한 근로자에 대해 효력이 발생하지 않는다는 논거와 모순되는 점, 둘째, 근로자의 동의를 받지 못하면 종전의 취업규칙이 계속 유효하고 변경된 취업규칙이 성립하지 않는 점, 셋째, 신규입사자에게만 예외를 두려고 하면 경과규정을 두거나 그 취지를 규정하는 방식으로 개정되어야 한다는 점을 근거로 삼는다. 개인적으로는 절대적무효설을 지지하나 일반적으로는 상대적유효설이 널리 인정되고 있다.

(2) 상위규범과의 관계

상대적유효설을 취해도 노동조합이 있는 사업장에서는 한계가 있다. 특히, 퇴직금에 관한 사항은 단체교섭의 의무교섭대상으로서 이는 단체협약에 의하여 변경되는 것이 원칙이다. 그러므로 노동조합이 반대함에도 불구하고 이를 취업규칙에 의하여 사용자가 일방적으로 변경할 수는 없다고 할 것이다.[140] 따라서 단체협약의 내용이 종전 취업규칙의 내용과 같다면 불리하게 변경된 취업규칙은 단체협약에 반하므로 노동조합에 가입한 신규입사자에게 무효가 될 수 있다는 논리가 성립할 수 있는 비판이 제기 된다.

(3) 동의를 받은 신규입사자

근로자집단의 동의를 받아 신규입사자에게 기존의 근로조건보다 저하된 근로조건을 적용시킨다는 것을 내용으로 하는 취업규칙을 변경하는 것은 가능하다. 이는 절대적무효설도 인정한다. 변경된 취업규칙을 신규입사자에게만 적용하면, 이 역시 종전의 근로조건이 없기 때문에 불이익하게 변경되는 논리도 성립하지 않는다는 견해도 발견된다.[141]

따라서 신규입사자에 대해 취업규칙 변경의 효력을 다루는 판례법리는 사회통념상 합리성을 기준으로 불이익변경 여부를 판단하고 있는 것으로 접근해야 할 것이라고 생각한다.

4. 이의제기시효

---

138) 대법원 2011.6.24. 선고 2009다58364 판결.

139) 하갑래, 앞의 책, 169쪽; 이병태, 앞의 책, 942쪽; 이상덕, “취업규칙의 불이익변경과 집단적 동의”,「노동법학」제46호, 한국노동법학회, 2013.6, 118쪽.

140) 이상윤, 앞의 책, 422-423쪽.

141) 하갑래, 앞의 논문, 780쪽.

근로자의 동의 없이 취업규칙을 불리하게 변경한데 대해 근로자가 이의를 제기치 않다가 10여년이 경과한 후 이의를 제기해도 금반언의 법리에 반하지 않는다는 판례의 입장을 감안할 때,[142] 이의제기의 시효는 없는 것으로 볼 수 있다. 시효가 없다는 것은 퇴직금 규정과 같이 아직 채권으로 발생하지 않은 경우에 해당되며 이미 성립된 임금채권은 3년의 시효를 적용받는다.

5. 소급추인

(1) 원칙

취업규칙을 변경함에 근로자의 권리를 소급하여 불리하게 변경하는 경우에도 불이익변경으로 인정된다.[143] 해당 근로자들이 불리하게 변경된 취업규칙에 대하여 사후에 동의하여 그 변경 당시로 소급적 효력을 발생하게 할 수도 있다. 이 경우 근로자 과반수의 사후적 동의는 기존 근로자에게는 변경된 취업규칙이 무효라 종전 취업규칙이 적용된다는 사정을 알고 있는 상황이어야 하고, 이를 알지 못한 경우에는 동의한 날 이후부터 효력을 가진다.[144]

(2) 동의주체

근로자집단의 동의 없이 불리하게 변경된 취업규칙이 과반수노동조합이나 근로자과반수로부터 소급해 추인을 받은 경우에는 그 효력이 인정된다.[145] 추인 당시에 과반수노동조합은 취업규칙개정이후에 설립되거나 이해관계가 있는 개정당시의 근로자들이 없더라도 동의주체가 된다.[146] 근로자들이 이의를 제기함이 없어 불리하게 변경된 근로조건을 적용받아 왔거나, 그러한 규정이 유효하다고 여기었거나 개인적으로 찬성한 사실만으로는 소급추인이 인정되지 않는 것으로 해석된다.[147]

(3) 소급방법

추인주체는 근로자측이 되며 새 근로조건의 결정이라는 형식을 취한다. 따라서 새로운 취업규칙변경방법을 취하거나 단체협약체결방식에 의해 이루어진다.[148] 단체협약에 소급추인을

142) 대법원 1991.9.24. 선고 91다17542 판결.
143) 대법원 1994.5.24. 선고 93다46841 판결.
144) 임종률, 앞의 책, 363쪽.
145) 대법원 1993.1.15. 선고 92다39778 판결; 대법원 1993.3.23. 선고 92다52115 판결.
146) 대법원 1997.2.11. 선고 98다55009 판결.
147) 대법원 1993.1.15. 선고 92다39778 판결; 대법원 1993.1.26. 선고 92다49324 판결 등.

규정하는 형식에는 특별한 제한이 없다. 무효인 변경이후 설립된 노동조합이 단체협약체결과정에서 '불리한 변경사항을 배제하자'고 요구하지 않으면 소급적동의로 본다는 판례가 있으나,[149] 불리하게 변경된 내용은 무효로서 취업규칙이 이미 존재하지 않는다는 점을 감안할 때 찬성할 수 없다.

(4) 한계

소급추인의 효력은 추인 이후에 그 사업장에 종사하는 근로자에 대해서만 생기고 그 전에 퇴직한 근로자들이나,[150] 단체협약효력확장제도의 적용을 받지 않는 비조합원에 대하여는 효력이 없는 것으로 해석된다.[151] 발생된 임금채권의 일부를 반납하는 것은 근로조건의 결정이 아니고 이미 결정된 근로조건에 대한 권리의 행사이므로 개별근로자의 자유로운 의사에 따를 때만 유효하고, 집단적동의방식만으로는 효력이 없다. 퇴직급여도 그 채권이 발생하지 않은 상태이나 기대이익이 상실되는 점에서 기득권박탈이 될 수 있어 근로자 개인의 동의가 없다면 이를 반납하는 행위는 부당하다. 소급추인의 효력을 널리 인정하는 판례의 태도에 대해서는 비판의 여지가 있다. 퇴직급여에 대해 채권이 발생하지 않았다는 이유로, 이미 근로한 기간에 대한 기준까지 낮추는 것처럼 근로자 개인의 동의를 받지 않는 상태에서 기득의 권리를 침해하는 소급추인은 위법의 소지가 있을 뿐 아니라 바람직하지도 않다.

6. 신고 및 주지의 효력관계

(1) 법적근거

근기법은 사용자를 대상으로 취업규칙에 대해 근로자에게 주지시키도록 하고 있다(제14조 제1항). 이 규정의 취지는 근로자의 무지에 편승해 사용자가 자의적으로 적용시키는 것을 방지하기 위함이다. 이에 따라 사용자는 근기법과 근기령의 요지와 취업규칙을 근로자가 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어 근로자에게 널리 알려주어야 한다. 또한 근기법은 더 나아가 주지의무를 위반했을 경우 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있다(제116조 제1항 제2호).

---

148) 대법원 2000.12.22. 선고 99다10806 판결.
149) 대법원 1992.7.24. 선고 91다34073 판결; 대법원 1997.6.10. 선고 95다34316 판결; 대법원 1993.3.23. 선고 92다52115 판결.
150) 대법원 2004.7.22. 선고 2002다57362 판결.
151) 대법원 1993.2.12. 선고 92다50447 판결; 대법원 1993.3.23. 선고 92다52115 판결; 대법원 1993.6.11. 선고 92다19316 판결.

(2) 주지방법과 효력

1) 주지의 방법

근기법이 요구하는 주지방법은 '근로자가 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 게시거나 갖추어 두는 것'이다. 다만, 효력과 관련하여 "법령의 공포에 준하는 철차로서 그것이 새규범인 것을 널리 종업원 일반으로 하여금 알게 하는 적당한 방법"을 인정하는 판례가 발견된다.[152] 일본의 「노동기준법」은 게시·비치 외에 서면교부, 컴퓨터 사용을 주지방법으로 명시하고 있다(제106조 제1항). 그러나 한국의 근기법은 전자방식에 대해서는 규정하고 있지 않는다.

2) 주지의 효력

주지의무를 위반한 취업규칙의 효력에 대해서는 견해의 대립이 있다. 먼저, 무효설은 관련 규정이 취업규칙의 법규범적 효력을 부여하기 위한 전제로서 근로조건의 내용을 명확히 알도록 하기 위한 것이므로 적절한 방법으로 주지하지 않는 취업규칙은 효력이 없다고 본다.[153]이 설은 취업규칙의 실효성을 중시하고, 효력요건성을 부인하면 경영지침과 구분이 되지 않는다는 점을 논리적 근거로 삼는다.

다음으로, 유효설에 따르면 사용자가 취업규칙을 게시 또는 비치하지 않더라도 이는 단속규정으로서 과태료를 부과받는 것은 별론으로 하고 그 취업규칙은 무효로 되지 않는다.[154] 그러나 무효설은 일본의 해석으로부터 영향을 받는 것으로 보인다. 일본의 취업규칙 제도는 불이익변경에 대해 개별적 동의를 요구하고, 그 예외로 합리성 법리를 채택하면서 주지를 취업규칙의 기본적인 효력요건으로 인정한다. 우리나라의 경우에는 사정이 다르다. 취업규칙을 작성하는 경우와 불이익하지 않게 변경하는 경우에는 집단적동의 없이 의견청취로 효력이 인정되므로, 주지 여부에 따라 근로자에게 불이익여부가 달라지지 않는다. 취업규칙을 불이익하게 변경하는 경우에는 집단적 동의가 없으면 효력이 없으므로, 집단적동의 과정이 변경하는 경우에는 집단적동의가 없으면 효력이 없으므로, 집단적동의 과정이 주지의 기능을 갖게 된다. 다시 말해서 주지여부에 따라 근로자의 근로조건이 더 불리해질 여지가 없다. 이 밖에도 무효설을 취하여 취업규칙 주지의무의 관련조문을 효력규정으로 보게 되면, 해석상

152) 대법원 2004.2.12. 선고 2001다63599 판결.
153) 대법원 2004.2.12. 선고 2001다63599 판결; 김유성, 앞의 책, 213쪽; 임종률, 앞의 책, 366-367쪽; 김형배, 앞의 책, 303-304쪽.
154) 서울고등법원 2013.11.22. 선고 2013누15202 판결; 이상윤, 앞의 책, 426쪽.

갈등이 발생한다.[155] 따라서 현행규정에 대한 해석론과 관련해서 보면 유효설이 타당하다고 생각한다.

(3) 효력발생 시기

취업규칙의 작성·변경은 의견청취 또는 동의, 행정관청에 신고, 게시 또는 비치의 순으로 이루어진다. 이 중 의견청취행위, 의견서제출, 신고, 게시 또는 비치는 효력발생요건으로 볼 수 있다. 취업규칙을 작성하거나 불리하지 않게 변경한 경우에 그 시점에 효력발생시기가 되는 반면, 불리하게 변경한 경우에는 근로자집단의 동의를 받은 시점이 효력발생시점이다.

155) 하갑래, 앞의 책, 173쪽. 첫째, 취업규칙 주지의무의 관련조문을 효력규정으로 보게 되면, 문맥상으로만 볼 때, 근기법이나 근기령의 요지를 주지시키지 않은 경우에 해당법령의 효력에 영향을 미친다. 둘째, 사용자가 근로자에게 유리한 조건이 신설되어 있는 취업규칙에 대해, 주지되지 않은 것을 이유로 효력을 부정하는 주장도 제시될 수 있다.

제5장 불이익변경법리의 문제점과 개선방안

제1절 불이익 판단구조 단순화

1. 불이익판단구조의 문제점

우리나라의 1953년 제정 근기법은 취업규칙의 변경에 대하여 근로자집단의 의견청취를 요건으로 하는 일본의 「노동기준법」 기본구조를 따랐다.[156] 이 기본구조에 따라 의견청취를 요건으로 하면 구속성을 갖지 못하며, 사용자의 편무성이 작용한다면 변경된 취업규칙의 효력에 대해 의문이 제기된다.

이러한 점을 감안하여 근로조건이 근로자에게 불이익하게 변경되는 경우 근로자집단의 동의가 필요하다는 판례법리가 형성되었고,[157] 1989년 개정 근기법은 취업규칙의 불이익변경에 대해 근로자집단의 동의를 도입하는 계기가 되기도 하였다. 또한, 취업규칙의 불이익변경에 대해 개별근로자가 아닌 근로자집단의 동의를 받을 경우 효력이 있음을 명시하고 있다. 따라서 취업규칙을 불리하게 변경함에 있어 근로자집단의 동의를 받지 못한 이상 개인적으로 동의한 근로자에게도 효력이 발생하지 않으며, 근로자 집단의 동의를 받는다면 개인적으로 반대하더라도 변경의 효력이 발생한다는 판례법리가 형성되어 입법에 의해 자연스럽게 법규범성이 받아들여지고 있다.[158]

그럼에도 불구하고 한국은 근로자집단의 동의를 받는 요건인 불이익변경에 대해 합리성을 기준으로 삼는 판례가 형성되었으며, 학설도 객관적기준설이 거의 통설적인 견해라는 것을 이미 앞에서 설명한 바 있다. 이에 따르면 취업규칙의 불이익변경 여부를 궁극적으로 근로자가 아닌 사용자가 판단하게 되므로 근로자집단의 참여를 보완하기 위해 동의조항을 마련한 근기법의 입법 취지가 반감된다. 또한, 합리성이 있으면 근로자집단의 동의를 받지 않아도 취업규칙의 효력이 있다는 판례들이 법리를 형성하면서 합리성에 포함되는 판단기준을 구체적으로 형성하고 있다.

따라서 한국은 일본과 다른 법체계임에도 불구하고 사회통념상 합리성을 중심으로 취업규칙의 불이익변경문제를 접근하고 있으며,[159] 사회통념상 합리성으로 접근한다는 것은 불이익변경의 판단주체가 근로자가 아니라 사용자라는 것을 받아들일 수밖에 없는 구조적 모순을 안고 있다.

---

156) 박효숙, “일본의 취업규칙에 의한 불이익변경 법리”, 「노동법학」 제50호, 한국노동법학회, 2014.6, 67쪽.
157) 대법원 1977.12.27. 선고 77다1378 판결 등 다수
158) 하갑래, 앞의 논문, 787-788쪽.
159) 이 정 외 2인, 앞의 보고서, 117쪽.

2. 기존 논의의 내용과 한계

근기법 제94조에 따르면 취업규칙을 변경함에 있어 불이익한지 여부를 먼저 파악한 후에 불이익한 경우에만 동의를 받도록 하는 2중적인 판단구조를 가지고 있다.[160] 이 판단구조에 따르면 불이익하게 변경된 취업규칙의 효력을 판단하는 기준은 '불이익변경 여부'와 '동의 여부'로 구분된다고 할 수 있다.

이에 대해 판례법리는 변경된 취업규칙의 효력을 판단하는 기준으로 일관되게 사회통념상 합리성을 제시하고 있고, 이를 적용하여 불이익변경여부를 판단해오다가 동의의 필요성 여부에까지 확대하는 변화를 보여주고 있는 것으로 평가된다. 사회통념상 합리성을 기초로 하여 불이익변경의 성립을 부정하면서, 취업규칙의 변경효력을 인정하는 판례법리는 불이익변경을 판단하는 주체를 사용자로 보는 것은 객관적기준설에 근거를 두고 있다. 즉 사용자가 불이익변경에 대해 합리성을 인정하게 되면, 근로자집단의 참여는 주지의 성격을 갖는 의견청취로 충분하게 되어 집단적의사결정과정이 무의미해진다.[161] 반면에 사회통념상 합리성을 들어 동의의 설립을 부정하면서 취업규칙의 변경효력을 인정하는 판례법리는 불이익변경에 대한 사용자 판단이 아닌 근로자집단의 의사결정에 두고 있다고 평가할 수 있다. 이는 취업규칙의 변경에 있어 불이익변경과 동의로 구성되어 있는 2중적인 구조에 대한 비판이 가능하다. 따라서 사용자가 일방적이고 편무적으로 작성하는 취업규칙에 대해 규범성을 인정하기 위해서 근로자가 집단적으로 참여할 수 있는 제도를 확보해 주어야 한다는 견해도 발견된다.[162]

그러나 취업규칙의 변경에 대하여 2중적인 절차를 인정하고 그 중 불이익변경의 주체를 사용자로 보는 객관적기준설은 일방성을 가지고 있어 이러한 목적에 부합하지 않는다. 아울러 2중적인 구조는 분쟁 요소를 제거하는데 효율적이지 못하며, 법원에 의해 분쟁이 해결되는 결과를 초래하기 때문에 근로조건자율결정원칙에도 배치된다고 생각한다.

3. 불이익 판단구조 개선방안

근기법 제94조는 앞에서 설명한 바대로 객관적기준설에 따라 중층적인 판단구조를 가진다

---

160) 하갑래, 앞의 논문, 788쪽.

161) 이승길 "취업규칙법제에 관한 입법론적 고찰", 「노동법연구회」 제8호, 서울대 노동법연구회, 1999 상반기, 95쪽. 의견청취는 사용자가 일방적으로 의견을 구한다는 점에서 주지의무와 비슷하다고 볼 수 있는데, 의견청취가 협의의무와 마찬가지라는 비판을 소개하면서 성실교섭의무를 고려할 때 협의의무는 의견교환의 성격을 가지므로 오히려 의견청취보다 근로자집단의 참여를 잘 보장한다는 의견을 제시하면서 협의의무제도로 전환해야 한다는 주장을 제기한다.

162) 하갑래, 앞의 논문, 789쪽.

고 해석할 수밖에 없다. 그러나 취업규칙 불이익변경의 주체를 판단함에 주관적기준설을 따라 취업규칙 변경의 효력을 근로자집단의 의사결정에 맡김으로써 불이익변경을 판단하는 것과 동의를 구하는 것을 구분할 이유가 없다고 생각한다. 왜냐하면 근로자의 의견을 확인하는 과정을 통해 과반수가 찬성하면 불리하지 않은 변경임을 확인하는 동시에 동의를 한 결과를 초래하기 때문이다. 반면에 과반수 미만이 찬성한다면 불이익변경임을 확인하는 동시에 동의를 하지 않은 결과가 된다. 따라서 작성할 때에는 의견청취를 요건으로 할 수 있겠으나, 변경할 때에는 동의가 요건이 되는 것이다.

현재 근기법 제94조는 2중적인 판단구조를 명확히 하고 있으므로, 주관적기준설을 기반으로 취업규칙변경제도를 재설계하면서 입법론적인 접근이 필요하다. 구체적으로는 취업규칙을 작성할 때는 근로자집단의 의견을 청취케 하고 변경할 때는 근로자집단의 동의를 받게 하도록 하는 견해는 타당하다고 생각하며,[163] 입법적 정비가 요청된다고 생각한다.

제2절 사회통념상 합리성법리의 법제도화

1. 사회통념상 합리성법리 적용형식의 문제점

근기법 제94조 제1항 단서규정에 따르면 동의를 얻지 못한 취업규칙의 효력은 원칙적으로 무효이다. 그러나 동의를 얻지 못한 취업규칙도 효력을 인정받는 경우가 있는데 대법원은 사회통념상 합리성이 있다면 근로자의 동의를 얻지 않아도 당해 변경이 유효하다고 판단한다. 대법원이 판시하는 '사회통념상 합리성'은 "변경의 필요성과 내용에서 보아 그에 의거 근로자가 받게 되는 불이익의 정도를 고려하더라도 당해 조항의 법적 규범성을 시인할 만한 합리성"으로 정리할 수 있다. 대법원은 취업규칙 변경에 있어 사회통념상 합리성으로 불이익변경 또는 동의필요성을 부정하는 방법으로 근로자집단참여제도의 적용을 완화해 왔다. 그리고 대법원의 이러한 해석은 행정해석이나 학설의 지지를 받아 노동현장에서 가이드라인으로 작용할 뿐 아니라 법리로 형성되고 있다.

따라서 판례법리로 형성되고 있는 합리성 판단의 내용은 그 논리적 결함과 적용의 한계를 명확히 해주면서 통일적이고 일괄되게 적용할 수 있도록 할 필요가 있다. 그러나 '사회통념상 합리성'이라는 개념은 추상적이고 예측가능성이 적어 분쟁을 사전에 예방하기에는 한계가 있다. 아울러 판례법리는 판단의 대상을 불이익변경여부에서 동의여부로 전환하는 변화를 거치면서, 그 범위를 크게 확대 하였다. 사회통념상 합리성의 범위가 넓어질수록 취업규칙의 규범성이 약화되어,[164] 궁극적으로는 근로조건의 저하로 이어질 수 있다는 비판이 가능하다.

---

163) 이 정 외 2인, 앞의 보고서, 118쪽.

2. 기존 논의의 내용과 한계

대법원은 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의 없이 근로자에게 불리하게 작성·변경된 취업규칙이라도 사회통념상 합리성이 있다고 인정되는 경우에는 그 적용이 가능한지 여부 및 합리성 유무의 판단 기준에 관해 비교적 명확하게 밝히고 있다.[165]

> "사용자가 일방적으로 새로운 취업규칙의 작성·변경을 통하여 근로자가 가지고 있는 기득의 권리나 이익을 박탈하여 불이익한 근로조건을 부과하는 것은 원칙적으로 허용되지 아니한다고 할 것이나, 당해 취업규칙의 작성 또는 변경이 그 필요성 및 내용의 양면에서 보아 그에 의하여 근로자가 입게 될 불이익의 정도를 고려하더라도 여전히 당해 조항의 법적 규범성을 시인할 수 있을 정도로 사회통념상 합리성이 있다고 인정되는 경우에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 없다는 이유만으로 그 적용을 부정할 수는 없다고 할 것이고, 한편 여기에서 말하는 사회통념상 합리성의 유무는 취업규칙의 변경에 의하여 근로자가 입게 되는 불이익의 정도, 사용자측의 변경 필요성의 내용과 정도, 변경 후의 취업규칙 내용의 상당성, 대상조치 등을 포함한 다른 근로조건의 개선상황, 노동조합 등과의 교섭 경위 및 노동조합이나 다른 근로자의 대응, 동종 사항에 관한 국내의 일반적인 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다."

대법원이 판시한 내용은 일본최고재판소 판결을 그대로 답습한 것으로 평가된다.[166] 일본 최고재판소 판결을 살펴보기 전에 일본 「노동기준법」을 먼저 살펴보면 1947년 제정된 일본의 노동기준법은 취업규칙에 관해서 제정 당초부터 총 5개의 조문을 두어서 취업규칙의 작성 및 신고의무(제89조), 작성절차(제90조), 제재규정의 제한(제91조), 법령 및 단체협약과의 관계(제92조), 근로계약과의 관계를(제93조) 규율해오고 있다.[167] 그런데 「노동기준법」에는 제정 당초부터 법령상의 불비점이 존재하고 있었고 이는 이후 취업규칙 불이익변경을 둘러싸고 벌어지게 되는 길고도 첨예한 논쟁의 원인으로 되었다.[168] 대표적으로 법령상 불비점은 취업규칙의 작성절차와 관련해서 사용자가 취업규칙을 작성・변경하는 경우에 있어서 사용자는 당해 사업장의 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 노

---

164) 이달휴, "취업규칙의 불이익변경과 사회통념상의 합리성, 「법과 사회」 제22호, 법과사회이론학회, 2002.6, 175쪽.
165) 대법원 2001.1.5. 선고 99다70846 판결.
166) 하갑래, 앞의 논문, 788쪽.
167) 이 정(譯), 앞의 책, 141-142쪽.
168) 정영훈, 앞의 논문, 176쪽.

동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자의 의견을 청취해야 한다고 하여 단지 청취의무만을 규정함으로써 사용자의 일방적인 취업규칙 제정·변경권이 관념지어지게 되었다는 평가를 받는다.

이러한 이론적 상황에서 1968년에 슈북버스(秋北バース)사건 최고재판소판결이 등장하고 이후 일련의 최고재판소 판결[169]이 슈북버스(秋北バース)사건에서 판단한 법리와 그 기준을 따르는 한편 이를 구체화하게 되면서 취업규칙의 불이익변경에 관한 새로운 법리가 확립하게 되었다. 이 법리가 바로 이른바 합리적 변경법리인데, 합리적 변경법리는 새로운 취업규칙의 작성 또는 변경에 의하여 근로자의 기득의 권리를 빼앗고 근로자들에게 불이익한 근로조건을 일방적으로 부과하는 것은 원칙적으로 허용되는 것이 아니지만 근로조건의 집단적·통일적·획일적 결정을 원칙으로 하고 있는 취업규칙의 성질로부터 당해 조항이 합리적인 것이라면 개개의 근로자가 이에 동의하지 않더라도 당해 조항은 개개의 근로자를 구속한다고 하는 것이다.[170] 합리적 변경법리에서 핵심은 불이익하게 변경된 취업규칙의 조항이 합리적인 것인가의 판단에 있다고 할 수 있는데, "근로자가 입는 불이익의 정도, 사용자측의 변경 필요성의 내용과 정도, 변경 후의 취업규칙 내용 자체의 상당성, 대상조치 기타 관련된 다른 근로조건의 개선상황, 노동조합 등과의 교섭의 경위, 다른 노동조합 및 다른 근로자들의 대응, 동종 사항에 관한 국내 회상의 일반적 상황 등을 종합적으로 고려해서 판단"되어야 한다고 한다. 이러한 판결내용이 「노동기준법」이 아닌 2007년에 제정된 노동계약법 제9와 제10조는 합리적 변경법리를 그대로 입법화한 하였다.[171]

슈북버스(秋北バース)사건의 영향을 받아 불이익변경에 대한 판례법리가 형성되고 입법에 반영된 것은 한국과 일본 모두 마찬가지이나 불이익변경의 요건에 대해서는 성격을 달리하고 있다. 일본의 의견청취에 대해 근로자대표 즉 근로자집단을 주체로 하고 있으나, 불이익변경을 위한 합의는 근로자를 주체로 하고 있다. 불이익변경을 위한 합의주체가 근로자집단으로 되어 있지 않음에 따라,[172] 묵시적 합의를 인정할지,[173] 다수로 구성된 노동조합과 소수로 구성된 노동조합 또는 비조합원의 관점에서 합의의 내용을 어떻게 적용할 것인지, 다수조합의 교정교섭의무의 문제나 소주조합과의 성실교섭의무를 인정할 것인지 등의 문제들이 쟁점이 되고 있을 뿐 아니라, 슈북버스(秋北バース)사건에 대해서도 계약설과 법규범설중 어디에 해당하는지에 대한 논란이 여전히 이어지고 있다.[174]

---

169) 御國ヘィャ事件－最二小判 1983.7.1.; タケダツステム事件－最二小判 1983.11.25.; 第四銀行事件－最大判 1997.2.28.; みちのく銀行事件－最一小判 2000.9.7.; 函館信用金庫事件－最二小判 2000.9.22. 등(하갑래, 앞의 논문, 786쪽 재인용).

170) 정영훈, 앞의 논문, 177쪽.

171) 이 정 외 2인, 앞의 보고서, 173쪽.

172) 노상헌, "일본근로계약법의 내용과 시사점", 「노동법학」 제26호, 한국노동법학회, 2008.6, 374쪽.

173) 荒木尙志, 『勞動法』, 有斐閣, 2009, 309-310頁(하갑래, 앞의 논문, 787쪽 재인용).

174) 이 정(譯), 앞의 책, 146-149쪽.

불이익변경에 대해 한국은 일본과 달리 개별적인 근로자가 아닌 근로자집단의 동의를 받을 경우 효력이 있음을 명시하고 있다. 따라서 취업규칙을 불리하게 변경함에 있어 근로자집단의 동의를 받지 못하면, 개인적으로 동의한 근로자에게도 효력이 발생하지 않게 된다. 근로자집단의 동의를 받는다면 개인적으로 반대하더라도 변경의 효력이 발행한다는 판례법리가 형성되어 입법에 의해 자연스럽게 법규범성이 받아들여지고 있다. 그럼에도 불구하고 한국은 근로자집단의 동의를 받는 요건인 불이익변경을 판단함에 있어 합리성을 판단의 기준으로 삼는 판례법리가 형성되었으며, 나아가서 합리성이 있으면 근로자집단의 동의를 받지 않아도 효력이 있다는 판례들이 나오면서 합리성에 포함되는 판단기준을 더 다양하게 하고 있다.

따라서 한국의 판례는 일본과 다른 법체계임이 분명함에도 합리성을 중심으로 취업규칙변경 문제를 접근하고 있다. 이는 일본의 판례들을 답습하고 있다는 비판이 가능하다.

3. 사회통념상 합리성법리의 개선방안

취업규칙은 사업장에서 중요한 근로조건 결정수단으로 활용되고 있다. 노동조합의 조직률이 10%대의 머무를 정도로 낮은 상황을 감안한다면 취업규칙제도가 단체협약을 대체하거나 보충하는 지위에 있다. 이러한 취업규칙은 사업장 내 근로조건 및 복무규율의 통일적 형성을 도모하고 최저기준 설정의 기능을 갖는다. 근기법은 취업규칙의 내용을 불이익하게 변경하고자 할 때 사용자의 일방적 조치는 법적 효력이 없으며, 근로자 과반수의 동의를 얻을 것을 요건으로 규정하고 있다. 이와 같은 내용으로 취업규칙이 정립되어도 경제나 경영 환경이 좋은 경우에는 별 문제를 야기함이 없었다. 왜냐하면 경제나 경영 환경이 좋은 경우 근로조건을 불이익하게 변경할 필요성은 특별한 경우에만 발생하기 때문이다.

그러나 1990년대 중반 IMF 전후로 기존 근로조건의 개선보다는 동결이나 하향조정이 불가피한 경우가 발생하게 되고, 그에 따라 취업규칙의 불이익변경이 불가피하게 요청되는 경우가 초래되게 되었다. 근로조건의 하향변경은 다수의 근로자의 반대에 부딪혀서 경제 환경에 대응하는 기업의 유연한 근로조건 형성 가능성을 기대하기 어렵게 되었다. 그 결과 기업의 존립을 위태롭게 하기도 하였으며, 기업 존립을 위해 필요한 경우 근로조건의 하향변경도 이루어낼 수 있도록 취업규칙을 유연하게 운영해야 함에도, 근기법은 취업규칙의 변경에 관해 여전히 엄격한 절차를 요구하고 있다.

대법원이 과반수동의를 얻지 않아도 불이익하게 변경된 취업규칙의 효력에 관하여 상대적 무효설의 입장으로 전환한 점, 사회통념상 합리성이란 이론을 적극적으로 수용 발전한 점 등도 이러한 맥락에서 이해할 수 있을 것이다. 다만, 취업규칙의 불이익 변경에 대해 법적근거 없이 합리성 법리를 적용하여 근로자집단의 동의를 면제시켜주는 것은 타당해 보이지 않고,

합리성에 대해 근기법의 동의 규정을 배제하는 효과를 가지므로 엄격히 해석해야 하나, 예외인 경우에 적용될 수 있도록 입법적으로 해결되는 것이 바람직하다고 생각한다.

구체적으로 사회통념상 합리성을 판단하는 기준에 대해서 판례법리를 기초로 보완한다면 "취업규칙의 변경으로 근로자에게 불리한 정도, 사용자측이 변경 필요성의 내용과 정도, 해당 업무의 성질, 취업규칙, 변경의 취지와 경위, 취업규칙 규정의 전체적인 체제, 변경된 취업규칙 내용의 상당성, 변경에 대신해서 행한 조치를 포함한 다른 근로조건의 개선상황, 노동조합 등과의 교섭 경위 및 노동조합이나 다른 근로자의 반응, 같은 사례에 관한 일반적인 정황, 동종 사업에 대한 일반상황, 동의가 불가능할 정도의 불가피한 사정의 유무, 변경으로 바로 불이익을 받는 사람이 현실적으로 없는지, 특정한 근로자 에게 불이익을 주려는 목적이 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다."고 명시할 수 있을 것이다.

그러나 취업규칙 변경의 합리성을 판단하는 것은 그 자체가 개별적이고 상대적인 성격을 가지고 있으므로 일반적인 기준을 제시하는 것은 여전히 사회통념상 합리성이 갖는 모호성과 주관성을 치유하기에는 한계가 있다. 이를 위해 근기법 시행령에 위임하고, 이때 합리성이 인정되는 개별적인 사유를 예시하는 방법을 제시하는 견해도 발견된다.[175] 이 과정에서 그 동안 판례법리로 형성된 내용을 명문화 한다면 법적안정성이 높아지는 효과를 기대 할 수 있을 것으로 생각한다.

제3절 동의의 효력에 대한 법제도화

1. 동의의 효력 적용형식의 문제점

취업규칙의 변경이 근로자에게 불이익함에도 근로자집단의 동의를 받지 못하였다면 이 취업규칙의 변경은 효력이 없고, 종전의 취업규칙이 계속 유효하다고 볼 것인지, 그 변경으로 기득이익이 침해되는 기존의 근로자들에게 대한 관계에서만 종전 취업규칙이의 효력이 유지되고, 그 변경 후에 근로관계를 갖게 된 근로자에 대한 관계에서는 당연히 변경된 취업규칙이 적용되어야 한다고 할지 각각에 대해 의문이 제기된다.

이에 관해 기존 취업규칙을 불이익하게 변경함에 있어 근로자집단의 동의를 받지 못하면 신규입사자 및 재입사자에 대한 효력은 상대적 유효설이 거의 통설적인 입장을 갖는다는 것을 이미 앞에서 설명한바 있다. 그러나 절대적 무효설의 논리적도 공감할 만하나, 통설적인 입장을 받아들일지 여부와 관계없이 입법론적으로 명확하게 할 필요가 있다.

175) 하갑래, 앞의 논문, 791쪽.

2. 기존 논의의 문제점과 한계

신규입사자 및 재입사자에 대한 취업규칙 변경의 효력을 다루는 판례는 궁극적으로 합리성을 기준으로 불이익변경 여부를 판단하고 있는 것으로 평가할 수 있다.[176] 아울러 취업규칙 변경과 관련하여 사회통념상 합리성의 범위가 확대되는 것은 취업규칙의 규범성을 제한하는 의미로 해석될 수밖에 없다. 아울러 합리성이라는 주관적인 개념에 의존함으로써 법적 안정성을 부정적인 영향을 미치는 점도 배제할 수는 없다.

따라서 사회통념상 합리성과 함께 동의의 효력과 관련하여 대법원 판례에만 맡기지 말고 입법적으로 해결방안이 모색되어야 한다.

3. 동의의 효력에 대한 개선방안

해석의 한계를 극복하기 위해 기존의 대법원 판례가 설시하는 내용을 입법적으로 명시하는 것을 고려할 수 있다. 구체적으로"취업규칙 변경의 필요성 및 내용이 근로자가 입게 될 불리함을 고려하더라도 변경된 조항의 법규범성을 인정할 수 있을 정도로 사회통념상 합리성이 있다면, 종전 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 없다는 이유만으로 그 적용을 부정할 수 없다."[177]는 원칙을 밝힐 필요가 있다. 여기서 그치지 말고 근로자집단의 동의를 받지 않을 수 있는 예외적인 사항을 규정하고 이에 대해 근로자집단의 의사결정과 과반수에 이르지 못하더라도 의견청취의 효력을 인정하는 제도적인 설계가 필요할 것이다.

176) 하갑래, 앞의 논문, 780쪽.
177) 이 정 외 2인, 앞의 보고서, 134-135쪽.

제6장 결 론

취업규칙은 사용자가 일방적으로 결정하는 편무성을 보완해야 한다. 이러한 이유로 근기법은 1953년에 제정되었을 때부터 취업규칙제도 도입하여 1989년 개정을 통해 취업규칙의 변경절차를 보완하여 근로자참여제도를 발전시켜왔다.

이를 기초로 대법원은 사회통념상 합리성이라는 기준을 적용하여 불이익 변경인지를 따져서 변경된 취업규칙의 효력을 판단해 왔다. 그러다가 최근 들어 대법원은 불이익변경 여부가 아닌 동의필요성 여부를 판단하기 위해 사회통념상 합리성을 따지는 구조적인 변화를 보여주고 있음을 확인하였다. 이러한 구조적인 변화는 기업경영이나 인사노무관리에 유연성을 확보하도록 사회통념상 합리성의 범위를 넓히려는 경향이 발견된다. 또한, 제한적이기는 하지만 현행 근기법상 취업규칙의 불이익변경을 기업의 외부 환경 변화에 적응하면서 근로자와의 고용관계를 지속할 수 있는 방안이 모색되어야 한다고 생각한다.

1953년 근기법 제정 당시 보다 2017년 현재까지 우리나라의 경제·사회는 급속도로 발전을 거듭하였다. 법적 안정성측면에서 보면, 경제·사회가 변함에 따라 법 개정도 당연히 수반되는 것은 아니지만, 수십 년이 지난 지금 과거에 만들어진 법과 지금의 현실과 비교를 해보면 괴리감이 작지 않다. 이런 관점에서 취업규칙 불이익 변경과 관련해서 기존의 입장을 유지할지 변화된 사회상을 반영할지 이 시점에서 검토해볼 필요가 있다고 생각한다. 본 논문은 불이익변경에 있어서 집단적 동의법리를 도입한 근기법의 입법목적을 실현하는 것에 주안점을 두되, 노동시장의 유연화를 극복할 수 있는 방안까지 염두 해 다음과 같은 개선방안을 제시하였다.

첫째, 근기법은 취업규칙을 변경함에 있어 불이익한지 여부를 먼저 파악한 다음에 불이익한 경우에만 동의를 받도록 하는 2중적인 판단구조를 단순화하여, 취업규칙을 작성할 때에 근로자집단의 의견을 청취케 하고 변경할 때는 근로자집단의 동의를 받게 할 수 있도록 제안하였다.

둘째, 취업규칙의 불이익 변경에 대해 사회통념상 합리성이 있는 경우 근기법의 동의 규정을 배제하는 효과를 가지므로 엄격히 해석해야 한다는 원칙은 유지하되, 예외인 경우에 이를 적용될 수 있도록 입법에 의해 제도화되는 것이 필요하다. 구체적으로 기존의 대법원 판례를 기초로 보완한다면 “취업규칙의 변경으로 근로자에게 불리한 정도, 사용자측의 변경 필요성의 내용과 정도, 해당 업무의 성질, 취업규칙 변경의 취지와 경위, 취업규칙 규정의 전체적인 체제, 변경된 취업규칙 내용의 상당성, 변경에 대신해서 행한 조치를 포함한 다른 근로조건의 개선상황, 노동조합 등과의 교섭 경위 및 노동조합이나 다른 근로자의 반응, 같은 사례에 관한 일반적인 정황, 동종 사업에 대한 일반상황, 동의가 불가능할 정도의 불가피한 사정의

유무, 변경으로 바로 불이익을 받는 사람이 현실적으로 없는지, 특정한 근로자에게 불이익을 주려는 목적이 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다."고 명시할 수 있다.

셋째, 사회통념상 합리성 법리를 적용함에 있어 동의의 효력까지 정비할 필요가 있다. 취업규칙이 불이익변경에 해당되더라도 법규범성을 인정할 정도로 사회통념상 합리성이 있으면, "종전 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 없다는 이유만으로 그 적용을 부정할 수 없다."는 원칙을 추가할 수 있다.

취업규칙 불이익변경법리는 노동법의 전체체계 및 노동시장의 고용관행 등과 함께 검토되어야 한다. 또한, 취업규칙제도 전체에 대한 심층적 검토, 노사협의회제도 및 근로자대표제도와의 연계, 독일의 사업장협정 및 변경해지제도의 도입 가능성 여부 등에 대한 면밀한 검토가 함께 이루어져야 할 것이다. 다만, 이 모두를 연계한 개선방안을 제시하지 못한 미비점이 있다. 이에 대한 연구는 후속 과제로 남긴다.

참고문헌

Ⅰ. 단행본

김유성, 『노동법 Ⅰ』, 법문사, 2005.

김지형, 『노동법해설』, 청출어람, 1993.

김치선, 『노동법강의』 제2판, 박영사, 1988.

김형배, 『노동법』 제24판, 박영사, 2015.

노동법실무연구회, 『근로기준법 주해 Ⅲ』, 박영사, 2010.

이병태, 『최신노동법』 제9판, (주) 중앙경제, 2008.

이상윤, 『노동법』 제14판, 법문사, 2015.

이 정(譯), 『日本勞動法』, 법문사, 2007.

임종률, 『노동법』 제14판, 박영사, 2016.

하갑래, 『근로기준법』 제29판, (주) 중앙경제, 2017.

Ⅱ. 논문

강성태, "노동개혁을 위한 노동법의 과제 - 근로시간·해고·취업규칙의 개정론을 중심으로 -", 「노동법학」 제56호, 한국노동법학회, 2015.12.

강희원·선미란, "취업규칙의 본질에 관한 일고찰", 「외법논집」 제37권 제2호, 한국외국어대 법학연구소, 2013.5.

김 철, "취업규칙제도에 관한 연구", 경희대 박사논문, 2010.2.

____, "취업규칙제도의 비교법적 일고찰", 「경희법학」 제45권 제4호, 경희대 법학연구소, 2010.12.

노상헌, "일본근로계약법의 내용과 시사점", 「노동법학」 제26호, 한국노동법학회, 2008.6.

박종희, "임금피크제와 취업규칙 변경 절차에 관한 법적 검토". 「노동법포럼」 제15호, 노동법이론실무학회, 2015.7.

박효숙, "일본의 취업규칙에 의한 불이익변경 법리", 「노동법학」 제50호, 한국노동법학회, 2014.6.

신권철 "취업규칙을 넘어 - 판례 법리와 그 비판 -", 「노동법연구」 제41호, 서울대 노동법연구회, 2016 하반기.

이달휴, “취업규칙의 불이익변경과 사회통념상의 합리성, 「법과 사회」 제22호, 법과사회이론학회, 2002.6.
이상덕, “취업규칙의 불이익변경과 집단적 동의”,「노동법학」 제46호, 한국노동법학회, 2013.6.
이승길, “취업규칙법제에 관한 입법론적 고찰”, 「노동법연구회」 제8호 서울대 노동법연구회, 1999 상반기.
정영훈, “취업규칙의 불이익변경에 관한 일고찰”, 「노동법학」 제31호, 한국노동법학회, 2009.9.
조득주, “취업규칙제도에 관한 연구”, 고려대 박사논문, 2008.2.
하갑래, “취업규칙 불이익변경에 있어 사회통념상 합리성”, 「법학논총」 제33권 제2호, 단국대 법학연구소, 2009.12.

Ⅲ. 보고서 및 기타 자료

노동부, 「근로기준법 연혁집」, 노동부, 2008.
이 정 외 2인, 「취업규칙 분석 및 제도개선 방안 연구」, 노동부, 2009.
임종률 외 7인, 「근로기준법제의 중장기적 개선 방안 연구」, 노동부, 2007.
고용노동부, 「직무능력과 성과 중심의 인력운영과 취업규칙 지침 설명자료」, 고용노동부, 2016.

(Abstract)

A Study on the Disadvantageous Change for the Rules of Employment

Jeon, Sang-Rock
Department of Labor Law
Graduate School of Legal Studies and Public Administration
Dankook University

Advisor : Professor Ha, Gap-Rae

To change employment rules to the disadvantage of workers, the employer should get approval of its labor union organized by the majority of workers (hereafter will be called "majority labor union"), or, if there is no such a union, the approval of the majority of workers. The reason why the Labor Standard Act prescribes requirements on disadvantageous change of rules is to protect workers by compensating the limits of employment rules which can be one-sidedly decided on by the employer unlike the cases of labor contract or collective agreement.

Employment rules work as collective norms regulating work relations in the workplaces where labor unions are not organized. working conditions are decided on the principle of equality of labor and management. Employment rules have tendency of one-sidedness where the employer

arbitrarily decides on given that they are accepted as law and ordinance in workplace. Thus, it is essential to have a systematic apparatus where workers can participate in to protect workers.

Majority labor union or approval of the majority of workers makes it difficult for the employer to respond resiliently to changing working conditions and management environment. For such reasons, the court have judged whether such changes are disadvantageous to workers, by applying the standard of rationality in common sense. Furthermore, the court established the legal principle that if there is common sense rationality the effect of employment rules is accepted without the approval of majority labor union or the majority of workers.

In other words, even if the Labor Standard Act clearly demands strict procedure called approval of majority labor union or of the majority of workers, it, to secure flexibility, also accepts the legal principle of rationality as a way to exclude approval clause.

Disadvantageous changes of employment rules depend on interpretations due to legal flaws and realistic considerations. But, relying too much on interpretations can weaken normalcy of employment rules, ultimately worsening working conditions. Accordingly, considering that the Labor Standard Act has some gap with the reality, and that it is not desirable to resort to interpretation on the effects of employment rules, this study wants to suggest a method of absorbing the contents of cases of the court into legislative sphere.

First, the system should be redesigned in the theoretical structure where the judgements over whether disadvantageous changes will occur, or over whether those changes will be approved in multi-layers, will be simplified. It needs to be redesigned where when employment rules are founded, opinions of the worker group will be considered, and, when those rules are changed, it is necessary to get approval of the worker group.

Second, rationality can effectively exclude approval clause of the Labor Standard Act, it should be applied exceptionally with the precondition of strict requirements.

Third, with the principle that legal principle of rationality should be applied exceptionally for disadvantageous changes of the rules, the effects of approval should also be evidently stipulated.

Key Words: employment rules, disadvantageous changes of employment rules, worker participation system, common sense rationality, approval subject and method, effects of approval.